

casa se ha considerado ciertamente excluido el arrendamiento de ésta. Pero encontrando excepcionalmente constituido un derecho de uso sobre fundos rústicos, la jurisprudencia se preocupó del suplicio de Tántalo que así se infligía al usuario. Es difícil decir hasta qué punto pueden haber llegado en sus concesiones los juristas; por cierto se admitió que el usuario pudiese hacer en el fundo un pequeño huerto, recoger frutos y flores y cortar leña, pero todo ello dentro de límites estrictos y con la reserva de consumición en el lugar. JUSTINIANO amplió, en cierto modo, estas concesiones y es sin duda suya la máxima de que el usuario puede tomar del fundo todo "quod ad victum sibi suisque sufficiat" (D. 7, 8, 12 § 1), como suya es la concesión de arrendar en parte la casa (fr. 4 pr. h. t.)⁹. Desde todo otro punto de vista, el régimen del uso es análogo al del usufructo.

Muy controvertida es la existencia jurídica de un *fructus sine usu*, que se verificaría cuando el uso se dejase a una persona, y el goce de los frutos a otra. Probablemente, para los clásicos es ésta más bien una construcción escolástica (análoga al *actus sine itinere*; cfr. p. 263) que una institución prácticamente aplicada¹⁰.

En cuanto a la *habitatio*, y a las *operae servorum*, objetos frecuentes de legado, los clásicos discutían si semejantes legados debieran considerarse constitutivos de usufructo o de uso o productores de simples derechos de crédito. JUSTINIANO los construyó como derechos especiales sobre la cosa ajena; residuo de la antigua construcción como derechos de crédito es la regla en virtud de la cual, a diferencia del usufructo y del uso, no se extinguen por *capitis deminutio*.

⁹ Cfr. sobre el tema: RICCOBONO, *Sull' usus*, en *Studi in onore di V. Scialoja*, 1904, I, ps. 579 y ss.; PAMPALONI, "Riv. Ital. per le Scienze Giur.", 49, 1911, ps. 241 y ss.; y los manuales de BONFANTE (10ª ed., p. 340) y de PEROZZI (I, 2ª ed., ps. 790 y s.).

¹⁰ Cfr. PAMPALONI, loc. cit., ps. 267 y ss. Probablemente, el único caso en que se tuviese por derecho clásico un *fructus sine usu* fuera el del concurso de varias disposiciones testamentarias (A instituye heredero a B, dejando el uso de un fundo a C; B, a su vez, deja a D el *fructus*); y aquí JUSTINIANO parece admitir que el *fructuarius* deba concurrir también en el uso. No me parece muy diversa la solución de MEYLAN, loc. cit. en la p. 284, n. 4, quien, sin embargo, atribuye a los justinianos una ampliación en la aplicación del f. s. u., mientras yo supondría, más bien, que ellos hubieran dejado por inadvertencia en el Digesto las menciones que sobre él hacían los clásicos.

§ 4. MODOS DE ADQUISICIÓN Y DE EXTINCIÓN, DEFENSA JUDICIAL DEL USUFRUCTO Y DE LAS SERVIDUMBRES

Los modos de constitución de las servidumbres y del usufructo imitan, en buena parte, los modos de transmisión del dominio; también aquí, en efecto, rige para los clásicos el principio de la insuficiencia del contrato para crear derechos reales.

Las servidumbres rústicas, que son —como se ha dicho— *res Mancipi*, pueden constituirse mediante *mancipatio* (no sabemos con qué modificaciones a la forma solemne de ésta, y sobre todo con qué sustitutivo del requisito de la presencia de la cosa). Servidumbres rústicas y urbanas, usufructo y derechos análogos se constituyen mediante *in iure cessio*, es decir, mediante una ficticia *vindicatio servitutis* o *ususfructus*, análoga a la ficticia *vindicatio rei* que hemos visto ya (p. 220).

Además, todos los derechos examinados pueden constituirse mediante *deductio* de la *mancipatio* o *in iure cessio* de la cosa sobre la cual se quiere que recaigan; así, un propietario puede mancipar o *cedere in iure* una cosa reservándose su usufructo, y el propietario de dos fundos puede, al transmitir uno de ellos, constituir una servidumbre sobre él, con relación al otro fundo que le queda. Sobre las cosas *nec Mancipi*, comprendidos los fundos provinciales, el usufructo se puede constituir también mediante el *constituto posesorio*, que puede considerarse casi una *deductio* de la *traditio* (cfr. p. 226). Entre los modos de adquisición a título originario, encuentra aquí aplicación solamente la *adiudicatio* y la *litis aestimatio*.

Para la constitución de los derechos sobre que tratamos, sirve también el legado *per vindicationem*; es más, mientras para las servidumbres este modo de constitución es raro, para el usufructo es el más practicado. No puede tener la misma eficacia el legado *per damnationem*, que crea solamente una relación obligatoria entre legatario y heredero; aquí corresponde que entre ellos se recurra a uno de los modos ya descritos de constitución *inter vivos*.

El paralelismo entre los modos de transmisión del dominio y los de constitución de las servidumbres y del usufructo habría importado la creación, para los *iura* no comprendidos entre las *res Mancipi*, de una institución análoga a la *traditio*. Pero los clásicos afirman "*res incorporales traditionem non recipere*" (GAYO, II,

28); JUSTINIANO admite, en cambio, sea en relación con las servidumbres rústicas, o con el usufructo, una *quasi traditio* que se expresaría con la *patientia*, es decir, permitiendo que otro entre en el ejercicio de aquéllas o de éste. Tal *patientia* no debe, sin embargo, entenderse como mera tolerancia (en cuyo caso se tendría, antes que un modo de constitución inmediata, una preparación para la prescripción adquisitiva), sino como la declaración de la voluntad de soportar ese ejercicio, declaración incorporada —por lo común— a un documento, y que representa en este campo el paralelo de la *traditio ficta* justinianeas (cfr. ps. 226 y ss.).

Parece que el derecho antiquísimo admitía la adquisición de las servidumbres por usucapición (probablemente a los dos años, como derechos inmobiliarios); una *lex Scribonia*, de fecha incierta pero indudablemente republicana, las declaró, en cambio, no usucapibles. No sabemos absolutamente nada a este respecto con relación al usufructo; es posible que, perteneciendo su difusión a un tiempo posterior a la *lex Scribonia*, no se haya nunca pensado en su usucapibilidad, o que esta última, reconocida en teoría, tuviese escasa aplicación práctica¹¹. El derecho justiniano reconoció, en cambio, una *longi temporis praescriptio* de las servidumbres rústicas y del usufructo; es incierto si se trata de una creación de JUSTINIANO o de una institución que se ha venido desarrollando sobre los fundos provinciales paralelamente al desarrollo general de la *praescriptio*¹².

¹¹ Para la usucapibilidad, cfr. BESELER, *Contributi*, 4, ps. 78 y ss. Un caso que se presenta espontáneamente al pensamiento es el de la *adiudicatio* de un usufructo como consecuencia de un *iudicium quod imperio continetur* (cfr. p. 207), y quizá a una hipótesis de este género se refería originariamente D. 6, 2, 11 § 1. Si en las mismas condiciones era adjudicada una servidumbre, el remedio lo daba probablemente el principio expresado en D. 41, 3, 10 § 1: "Hoc iure utimur, ut servitutes per se nusquam usu capi possint, cum aedificiis possint"; en un juicio divisorio, en efecto, la servidumbre debía adjudicarse conjuntamente con el fundo en cuyo favor preexistía o se constituía. PEROZZI (*Ist.*, 2ª ed., I, p. 772, n° 2) considera interpolado el texto; pero, aparte de las dudas que pueden surgir en torno al caso particular, la misma concepción de la servidumbre como inherente al fundo, *qualitas fundi*, importa que, una vez asignada una servidumbre, su adquisición sea simultánea con la del fundo dominante.

¹² La limitación de la *quasi traditio* y de la *praescriptio* a las servidumbres rústicas, que de las fuentes no resulta bien clara, parece sugerida por la observación de que ellas son normalmente positivas y discontinuas, mientras las urbanas son positivas y continuas (cfr. p. 262). Véase también el paralelismo con el *non usus*, reconocido como causa de extinción para las servidumbres rústicas y no para las urbanas.

Sobre los fundos provinciales, no susceptibles ellos mismos ni de *mancipatio* ni de *in iure cessio*, las servidumbres y el usufructo no habrían podido constituirse con estos negocios. Por eso se debió recurrir a medios indirectos; y sobre todo, puesto que estaba ya en el uso romano obligarse por estipulación a respetar el ejercicio de una servidumbre o del usufructo, a una estipulación semejante se le dió en las provincias el valor de acto constitutivo del derecho real. A esto conducía también la imitación de las instituciones vigentes en las provincias, donde precisamente la diferenciación entre los derechos reales y las obligaciones (y —respectivamente— entre los actos constitutivos de los primeros y los contratos) no era tan notable como en Roma, y, por el contrario, el uso era extender los efectos de un contrato, aparte que a los herederos, también a los adquirentes a título particular. Los formularios romanos deben haber sido modificados en los orígenes bastante ligeramente, y por ejemplo ha podido permanecer intacta la estipulación “*neque per te neque per venientes a te personas fieri, quo minus mihi ire agere liceat*”; pero mientras para los fundos itálicos permanecía firme el concepto de que “*venientes a te personae*” eran solamente los herederos y los otros sucesores universales, en provincia se debió haber seguido una interpretación más amplia. Para indicar estos singulares negocios jurídicos, que aunque tienen una estructura contractual constituyen derechos reales, los juristas del tiempo de GAYO usaron la expresión *pactiones et stipulationes*, que encuentra su aplicación en la circunstancia de que la idea del pacto (*pactum* o *pactio*) está menos ligada que la del *contractus* a la función específica de la creación de obligaciones (véase, por ejemplo, el nombre de *conventio pignoris*, o de *pactum hypothecae*, dado al acto de constitución del derecho real de hipoteca: ps. 292 y ss. y 395). En la época justinianeá, las *pactiones et stipulationes* sirven para constituir servidumbres sobre toda especie de fundos, y sustituyen las formas desaparecidas de la *mancipatio* y de la *in iure cessio*¹³.

El derecho justiniano parece, en fin, admitir, pero más bien en ciertos casos esporádicos que como principio general, el modo

¹³ Sobre la *traditio*, la *l. t. praescriptio*, las *pactiones et stipulationes*, hay una extensa literatura. Cfr. para todas PEROZZI, cuyo estudio (“*Riv. Ital.*” cit., 23, 1897, ps. 3 y ss., 167 y ss.) plantea la cuestión en sus términos exactos; después ALBERTARIO, “*Filangieri*”, 1912, ps. 207 y ss.; RABEL, *Mélanges Girard*, II, ps. 387 y ss. (demasiado conservador, especialmente

de constitución de las servidumbres que los modernos llaman *destino del padre de familia*; es decir que mediante la enajenación se trasformen en servidumbres los servicios que de hecho, pero permanentemente, prestaba un fundo a otro cuando su propietario era único¹⁴. El derecho clásico parece haber admitido solamente que una servidumbre (por ejemplo, de acueducto), constituida sobre varios fundos, pudiese considerarse como única, y en consecuencia permanecer intacta aun si temporariamente el propietario de uno de los fundos sirvientes fuese también propietario del dominante (D. 8, 3, 31).

*
* *
*

Servidumbres y usufructo se extinguen, ante todo, mediante actos iguales y contrarios a aquellos con los cuales se constituyen: mediante *mancipatio* las servidumbres rústicas, mediante *in iure cessio* todas las servidumbres y el usufructo, las servidumbres también mediante legado (en la hipótesis de que el propietario del fundo dominante quiera beneficiar al del fundo sirviente). En todo caso, estos actos valen en cuanto cumplidos con relación al propietario gravado; una *mancipatio* o *in iure cessio* de servidumbre o de usufructo en favor de extraños no podría tener efecto útil, por ser las servidumbres inseparables de la

para la *traditio*); BESELER, *Contributi*, 4, ps. 82 y ss.; MASCHI, *Bull. Ist. Dir. Rom.*, 46, 1940, ps. 174 y ss.; y (en particular sobre las *pactiones et stipulationes*) GROSSO, "Stud. e Docum.", 7, 1941, ps. 197 y ss.; BIONDI, *Serv. pred.*, ps. 215 y ss.; SOLAZZI, *Reg. e modi di cost.*, ps. 109 y ss.

Un pasaje del Digesto (4, 7, 1 pr.) habla de *ususfructus tuitioe praetoris constitutus*; esta frase, que parecía referirse principalmente a la *quasi traditio*, ha hecho que los tres medios últimamente analizados fueran corrientemente indicados como modos pretorios de adquisición. Pero del texto citado se tiene en los fragmentos Vaticanos (61) la versión genuina, y, aunque ésta esté mutilada, es fácil advertir que no se habla allí ni de *traditio* ni de *tuitio praetoris*, sino que solamente se contraponía al usufructo propiamente dicho el que se tenía sobre los fundos estipendiarior y tributarios (cfr. BESELER, p. 84). Cesa, en consecuencia, toda razón para conservar la denominación de servidumbre pretoria, tanto más singular cuanto en los modos de adquisición examinados (en cualquier límite que se quieran considerar clásicos) el pretor no entra ni mucho ni poco. Así también SOLAZZI, *Reg. e modi cost.*, ps. 137 y ss.

¹⁴ Cfr. RICCONO, *La destinazione etc.*, en "Riv. Ital. Sc. Giur.", 1896, ps. 380 y ss.

propiedad del fundo dominante y el usufructo intrasmisible. Sin embargo, en cuanto a la *in iure cessio* del usufructo en favor de extraños, los juristas romanos partieron de la consideración de que esta institución implica, antes que una enajenación, una renuncia; si en tal hipótesis la voluntad de enajenar no puede tener efecto, subsiste la voluntad de renunciar, y, en consecuencia, el usufructo cesa, recuperando su plenitud el derecho de propiedad¹⁵.

Servidumbres y usufructo se extinguen, además, todas las veces que propiedad y *ius in re* llegan a reunirse, por cualquier razón, en la misma persona: lo cual se llama para las servidumbres *confusio*, y para el usufructo, *consolidatio*. Ya se ha visto cómo se extingue el usufructo cuando la cosa pierde su actual estructura (por ejemplo, por el derrumbamiento del edificio); a su vez, las servidumbres se extinguen si los fundos dejan de estar dispuestos de modo que uno pueda prestar al otro el servicio que constituía el objeto del derecho¹⁶.

Otro modo de extinción es el no uso, que consiste en no ejercer durante cierto tiempo las facultades comprendidas en el usufructo o en la servidumbre. El tiempo es el mismo de la usucapión o de la prescripción adquisitiva de inmuebles: en el derecho clásico, dos años; en el derecho justiniano, diez años *inter praesentes* y veinte *inter absentes*. Pero el no uso no es igualmente aplicable a todos los derechos en examen; para el usufructo, en efecto, y para aquellas servidumbres cuyo ejercicio consiste en una actividad positiva del propietario del fundo dominante (como las servidumbres de pasaje, *aquae haustus*, *harenae fodiendae*, etc.), se comprende el valor del no uso; pero para las servidumbres cuyo ejercicio no requiere la obra del hombre (*stillicidii*, *cloacae*, *altius non tollendi*, *ne luminibus officiatur*, etc.) no se puede decir correctamente que el propietario del fundo dominante use de ellas ni que no use. Para su extinción se requiere que el propietario

¹⁵ Algo semejante ocurre si el *dominus proprietatis* manumite al esclavo sobre que pesa un usufructo de otro. El esclavo no adquiere la libertad; pero si la manumisión ha tenido lugar *vindicta*, es decir mediante *in iure cessio*, se tiene por firme la renuncia que el propietario ha hecho, y el esclavo permanece *sine domino*, ocupable como toda *res nullius*.

¹⁶ Sobre los límites en que esto sucede, y en particular sobre el problema del renacimiento de la servidumbre en caso de restablecimiento de la precedente situación, cfr. GUARNERI-CITATI, "Bull. Ist. Dir. Rom.", 43, 1936, ps. 19 y ss.; BIONDI, *Categoria*, ps. 278 y ss.; SOLAZZI, *Specie ed estinz.*, ps. 183 y ss.

del fundo sirviente ejecute un acto contrario a su existencia, y que el propietario del fundo dominante no se oponga a ello por todo el tiempo normalmente requerido para la usucapión o prescripción (*usucapio libertatis*). El derecho romano aplica el régimen del no uso a las servidumbres rústicas, que son normalmente del primer tipo, y el régimen de usucapión de libertad a las urbanas, que son, normalmente, del segundo tipo; mucho más oportunamente¹⁷ el derecho actual establece la distinción sobre la base de la discontinuidad o continuidad, es decir, de ser o no requerido para el ejercicio de cada servidumbre el hecho del hombre (art. 1073, Cód. ital. 1942).

*
* *

Para tutela del usufructo y de las servidumbres existen acciones *in rem* en cuya *intentio* se afirma "A° A° ius esse fundo Capenate utendi fruendi", o "per fundum Cornelianum eundi agendi", o "in aedes N° N° tigni inmittendi", etc. Perfectamente análoga, pero inversa, es la estructura de las fórmulas con las cuales el propietario de la cosa que se pretende gravada afirma la inexistencia del usufructo o de la servidumbre: p. ej., "N° N° ius non esse fundo Capenate utendi fruendi", etc. Por la partícula negativa que normalmente está contenida en este segundo tipo de fórmulas¹⁸, las acciones eran llamadas por los clásicos *negativae*

¹⁷ Hay, en efecto, servidumbres rústicas continuas, como el acueducto, a las cuales el régimen romano se adapta mal.

¹⁸ Normalmente, no siempre; si la servidumbre es negativa, es la *intentio* de la *vindicatio servitutis* la que gramaticalmente es negativa, mientras la de la *negatoria* es afirmativa. Por ejemplo, la *intentio* "N° N° ius non esse invito A° A° altius tollendi aed. suum" pertenece a la fórmula confesoria de la servidumbre *altius non tollendi*, mientras la *intentio* "A° A° ius esse invito N° N° altius tollendi" pertenece a la correspondiente fórmula *negatoria*. Quizá el discurrir que se trata en nuestras fuentes de servidumbre *altius tollendi*, *luminibus officiendi*, etc. (p. ej., en GAYO, II, 31, sospechado de glosema por SOLAZZI, *Per il XIV cent. delle Pand.*, Pavia, 1934, ps. 344 y ss.), deriva precisamente de una confusión de ideas alimentada por dichas fórmulas procesales. De acuerdo sustancialmente conmigo, GROSSO (*Studi Albertoni*, 1, 455 n.) considera derechamente que el nombre de la *a. negativa* haya sido dado por los clásicos precisamente a las fórmulas que tuvieran la partícula de negación, y que el concepto dogmático de la *negatoria* sea posclásico: punto

(GAYO, IV, 2), quizá también *negatoriae*; para contraponerles las acciones con las cuales se reivindicaban usufructo y servidumbres por el titular, JUSTINIANO (y quizá también antes que él la jurisprudencia posclásica) las llamó *confessoriae*, y mediante interpolaciones introdujo esta terminología en el Digesto¹⁹. Los clásicos hablaban, en cambio, de *vindicatio* (o *petitio*) *usufructus* (o *servitutis*): cfr. las rúbricas, evidentemente tomadas del Edicto, de D. 7, 6 ("si usufructus petetur [léase petatur] vel ad alium pertinere negetur") y de D. 8, 5 ("si servitus vindicetur vel ad alium pertinere negetur").

En el edicto estaban propuestos solamente algunos paradigmas de fórmulas: eran las (confesoria y negatoria) del usufructo, no del uso ni del *fructus sine usu*; y después las de las servidumbres de pasaje (*iter* y *actus*, cfr. p. 263), *altius non tollendi*, *oneris ferendi*²⁰, *tigni inmittendi*; en otra parte del *album*, al lado de la *actio aquae pluviae arcendae*, estaban las fórmulas para la *s. aquae ductus*.

Las acciones para las servidumbres competen fundamentalmente entre los propietarios del fundo dominante y del sirviente. Era natural que en la práctica tuviese a veces el propietario del fundo dominante que intentar la *vindicatio servitutis* contra el simple poseedor del sirviente, y podía también ocurrir que éste aceptase la *litis*, para no declarar que no era propietario; pero esto no impide que las acciones correspondan "*domino et adversus dominum*" (ULPIANO, D. 8, 5, 6 § 3).

sobre el cual no me animaría a seguirlo. Para el derecho justiniano. BIONDI y CIAPESSONI (véase más arriba, p. 202, n. 4) creen en la existencia de servidumbres legales del contenido indicado; contra GROSSO, "Stud. e Docum.", 6, 1940, ps. 239 y ss., y SOLAZZI, *Specie ed estinz.*, ps. 90 y ss. (allí también la crítica de la opinión de DI MARZO, *Studi Eesta*, 1, ps. 113 y ss., que cree en la clasicidad de la *serv. altius tollendi*).

¹⁹ SEGRÈ, *La denominazione dell'actio conf.*, en *Mélanges Girard*, II, ps. 511 y ss.

²⁰ También la fórmula relativa a esta servidumbre se inspira en la excepcional regulación de la *refectio*: cfr. p. 262. A la contraria opinión de SEGRÈ, "Bull. Ist. Dir. Rom.", 41, ps. 59 y ss., defendida también por GROSSO, *op. cit.* en la p. 195, n. 1, ps. 191 y ss., obsta insuperablemente D. 8, 5, 6, 2 *ad vv* "ut possit quis defendere ius sibi esse cogere adversarium reficere parietem ad onera sua sustinenda", donde está claramente reproducida la *intentio* (antes corregiría aquel incoherente *defendere* por *intendere*).

En cuanto a la *vindicatio ususfructus*, corresponde también ella por derecho clásico, contra el *propriarius* o *dominus proprietatis* que no consiente al titular el ejercicio del usufructo; sólo JUSTINIANO, según parece, tiende a hacerla ejercible contra quien quiera que se arrogue sobre la cosa un derecho cualquiera, se comporte, por ejemplo, como usufructuario o hasta como titular de servidumbre²¹. Un problema de difícil solución es, en cambio, el de la concurrencia entre la *rei vindicatio* y la *negatoria ususfructus*; quizá la primera competa en el caso de usufructo concluido, cuando con la conservación de la cosa el ex usufructuario demuestra quererla poseer desde entonces en adelante a nombre propio, y la segunda contra quien injustamente se arrogue un derecho de usufructo.

Bajo todo otro aspecto, el régimen de las acciones confesorias y negatorias parece modelarse sobre el de la *rei vindicatio*. Demandado es quien se halla de hecho en el ejercicio del usufructo o de la servidumbre, o en la posesión de la libertad del fundo del derecho de que se jacta el actor; actor, quien tiende a destruir el actual estado de posesión. Si el demandado no presta la *cautio iudicatum solvi* (cfr. p. 241), la posesión se considera trasferida a la contraparte, y, en consecuencia, al ejercicio de la negatoria por parte de uno se sustituye la confesoria intentada por el otro, y viceversa. Después de la *pronuntiatio de iure*, el demandado puede liberarse, por lo común, con la restitución, que en materia de usufructo consiste en entregar la cosa, en materia de servidumbre en abandonar el ejercicio del pretendido derecho o consentirlo a la otra parte, en restituir los lugares al primitivo estado si se hubieran construido obras no compatibles con la situación jurídica reconocida por el juez, en dar caución de no turbar ulteriormente a la contraparte²²; en cuanto esta restitución no tenga lugar, se

²¹ Sobre estos problemas, como sobre el de la legitimación pasiva en la *vindicatio servitutis*, véase Grosso (cit. en p. 195, n. 1), ps. 124 y ss. Sobre muchos puntos él logra captar las fases de una lenta evolución que ha llevado desde el punto de partida preclásico hasta el punto de llegada justiniano; sobre otros, en cambio (p. ej., sobre el sentido a darse a la legitimación pasiva del poseedor respecto a la *v. u. f.*), no puedo estar de acuerdo con el ilustre colega.

²² El falso usufructuario debe, naturalmente, restituir también los frutos, probablemente en los límites en que a ello está obligado el poseedor frente al dueño reivindicante, y con la misma distinción entre buena y mala fe. Ninguna pretensión a frutos podía, en cambio, tener lugar en

aplica la condena pecuniaria con el resultado común de que, pagando el vencido la *litis aestimatio*, la servidumbre o el usufructo nace donde no existía, o se extingue donde existía. Todo ello por derecho clásico; en derecho justiniano, el principio de la ejecución *manu militari* se impone también aquí, haciendo que el estado de hecho sea puesto, aun contra la voluntad del demandado vencido, al unísono con el derecho.

Según declaraciones de autores bizantinos, contemporáneos y posteriores a JUSTINIANO, que parecerían encontrar algún apoyo en dos pasajes del Digesto (7, 6, 5 pr. y 8, 5, 11), al mismo fin que la acción negatoria (o a un fin tan análogo que difícilmente se percibe la diferencia) habría tendido también una acción prohibitoria, en cuya intentio se afirmaría "ius A° A° esse prohibendi N^m. N^m. uti frui" (o "ire agere", o análogamente). Entre las diversas opiniones sostenidas sobre el particular por los romanistas, parece preferible la que considera que esta acción prohibitoria sea una construcción bizantina, sugerida quizá por aspectos posclásicos de la *operis novi nuntiatio*²³.

un juicio de servidumbre; es éste, probablemente, el sentido originario de la máxima *fructus servitutis esse non potest*, mal aplicada por los justinianos en D. 8, 3, 33 § 1 (donde están interpoladas, en mi opinión, las palabras "neque servitutis fructus constitui") y peor trasformada en D. 33, 2, 1 ("quia servitus servitutis esse non potest" interpolado: LONCO).

²³ Para las diversas opiniones cfr. en particular ZACHARIAE, "Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft" ["Revista de Jurisprudencia Histórica"], 12, 1849, ps. 258 y ss.; KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte* [Historia del derecho romano], II, ps. 470 y ss.; LENEL, "Rev. Fundac. Savigny", 2, 1881, ps. 72 y ss., y *Ed. perp.*, 3ª ed., p. 190; FERRINI, *Opere*, 2, ps. 145 y ss.; BORTOLUCCI, "Bull. Ist. Dir. Rom.", 21, 1909, ps. 113 y ss.; RICCOBONO, *Essays in legal history* cit., ps. 63 y ss.; HENLE, *Unus casus*, Leipzig, 1915, ps. 138 y ss.; BIONDI, "Annali Ist. Giur. Messina", 3, 1929, ps. 3 y ss.; por último, no más afortunado que los otros, SOLAZZI, *Spec. ed est.*, ps. 146 y ss. La llave está en D. 7, 6, 5 pr., donde las palabras "vel sibi ius esse prohibendi" se revelan interpoladas por el error de sintaxis, que las hace depender del verbo *negat*; también en D. 8, 5, 11, las palabras "ius sibi prohibendi esse vel" están fuera de lugar en un discurso totalmente basado sobre el juego de fórmulas procesales concebidas sobre el *ius esse* o *non esse*. Que después escritores de la época justiniana, como Teófilo y Esteban, se sirvan en esta materia de expresiones inspiradas en la técnica formularia, no basta para probar la clasicidad de la *a. prohibitoria*; las experiencias de recientes estudios han demostrado que a menudo aquellos maestros, respetuosos como su emperador de la antigüedad y adoctrinados en los escritos de la jurisprudencia antigua, derivaban para ilustración de tendencias totalmente nuevas los modos y el lenguaje de los clásicos.

Sobre los interdictos que tutelan el ejercicio del usufructo y de las servidumbres como tales, nos ocuparemos en el capítulo sobre la posesión y la cuasi posesión (cap. XI). Aquí corresponde, en cambio, referirse a otros interdictos que son ofrecidos a los titulares de servidumbres contra el propietario del fundo sirviente que se oponga a la ejecución de las obras destinadas a asegurar su funcionamiento: así, el *interdictum de itinere actuque reficiendo*, otorgado al titular de una servidumbre de pasaje contra el propietario que le prohíbe reparar la calle o el sendero; el *i. de rivis*, otorgado al titular de un acueducto para poderlo limpiar y mantener en buen estado; el *i. de fonte reficiendo*, para obras análogas en servicio del *aquae haustus*; el *i. de cloacis*, en fin, concedido a quien quiere reparar los desagües.

Otros medios judiciales pueden ser necesarios para tutela del mejor goce de una servidumbre o de la inmunidad del fundo sirviente por los daños que ella podría ocasionar: *cautio damni infecti, operis novi nuntiatio, interdictum quod vi aut clam*.

En el derecho justiniano se conceden al usufructuario y contra el usufructuario varias de esas acciones que competen normalmente entre propietarios de fundos para garantizar el mejor goce de los fundos mismos (en particular, la *a. aquae pluviae arcendae*); es muy controvertido en qué medida esta extensión al usufructo se remonta hasta la época clásica, pero indudablemente la tendencia a considerar al usufructuario como representante de los intereses objetivos del fundo es, en general, un producto de la última evolución del derecho romano.

CAPÍTULO IX

ENFITEUSIS Y SUPERFICIE

En el derecho justiniano, ambas son formas de propiedad limitada, con contenido económico y protección jurídica imitados más bien del dominio que de los derechos sobre cosas ajenas; y una y otra representan el término de una evolución que tuvo como punto de partida las concesiones administrativas del Estado y de los otros entes públicos.

*

* *

El nombre puramente griego de la enfiteusis (ἐμφύτευσις)¹ designa, desde la época de las repúblicas helénicas libres, la relación que se constituye como consecuencia de la concesión de tierras por parte de entes públicos o sagrados a los particulares, a perpetuidad o por largo término, mediante la contraprestación de un canon normalmente anual, a veces también capitalizado en una suma a pagarse de una sola vez, pero entendiéndose siempre que el concesionario adquiere sólo el goce de la tierra, y que el ente público concedente conserva su propiedad. Tal con-

¹ Para la historia cfr. MITTEIS, *Zur Geschichte der Erbpacht im Altertum* [Sobre la historia de la enfiteusis en la antigüedad], 1901, y las vastas investigaciones de ROSTOVTZEFF, especialmente en los *Studien zur Geschichte des römischen Kolonates* [Estudios sobre la historia del colonato romano], Leipzig, 1910; mucho de bueno hay en los tres *Studi sull'ager vectigalis* de LANFRANCHI (1938-1940). Para la dogmática del derecho justiniano, como también para el desarrollo posterior en Occidente, es fundamental la obra de SIMONCELLI, *Dell'enfiteusi* (en el *Cod. Civ. italiano* de FIORE).

cesión tiene comúnmente por objeto tierras incultas o deficientemente cultivadas, que el concesionario se compromete a labrar.

En el derecho romano clásico no existe una institución de este nombre; pero su contenido esencial se encuentra, con distintos matices, en las diversas concesiones de tierra por parte de la ciudad o de otros entes públicos, y en particular en el *ius in agro vectigali*. El nombre de *ager vectigalis* se da a los terrenos de comunidades dependientes de Roma (*coloniae* y *municipia*), que son concedidos por las mismas comunidades a particulares, con la obligación de pagar un canon anual (*vectigal*), y con la cláusula de que, mientras se pague puntualmente el canon, no puedan ser desposeídos ni el concesionario ni sus herederos, ni aquellos a quienes ellos hubiesen transmitido la tierra a título particular. Para describir esta institución, los jurisconsultos usan con frecuencia la terminología de la locación (cfr. por ejemplo, D. 6, 3, 1 pr.: "*vectigales vocantur qui in perpetuum locantur, etc.*"); pero GAYO (III, 145) recuerda que se discutía si en la concesión se debía ver una locación o una venta. La idea de la locación era sugerida por el pago del canon anual y también por el hecho de que cualquier suspensión en el pago mismo y (según parece) en las obras de cultivo, determinaba la revocación de la concesión; por otra parte, la normal perpetuidad y la transmisibilidad del derecho hacían más próxima la analogía con la venta. De todos modos, la transmisibilidad (unánimemente reconocida por la jurisprudencia) hacía surgir la eventualidad de controversias sobre la pertenencia del derecho a una u otra persona; se sintió la necesidad, en consecuencia, de otorgar al concesionario o a su derechohabiente una acción análoga a la *rei vindicatio*, que encontró lugar en el Edicto después de la fórmula de ésta, bajo la rúbrica "*si ager vectigalis petatur*"². Reproduciendo en D. 6, 3, alguna parte de los comentarios a la fórmula clásica, los justinianeos reprodujeron también la rúbrica edictal, pero introdujeron en ella, después de la palabra *vectigalis*,

² No me decido a adherirme a la opinión que hoy se va difundiendo (ver especialmente SCHILLING, *Studien aus der röm. Agrargeschichte* [Estudios sobre la historia agraria romana], Riga, 1926, ps. 60 y ss.; BESLER, "Stud. et Docum.", 3, 1937, ps. 360 y ss.) en el sentido de un origen tardío (posclásico) de esta *actio in rem*. La tesis no debe confundirse con la de ALBERTARIO, "Riv. Dir. Proc. Civ.", 5, 1928, ps. 185 y ss., que hace cuestión solamente de terminología.

el inciso *id est emphyteuticarius*, y la misma identificación se introdujo en otros lugares; con esto, trasportaban la regulación clásica del *ius in agro vectigalis* a una institución nueva y difundida, derivada de un largo desarrollo histórico que se había cumplido en las provincias, desarrollo sobre el cual convendrá decir algunas palabras.

Ya otra vez (p. 205) dijimos que el territorio de las provincias era en su totalidad de propiedad del Estado romano (provincias senatoriales) o del príncipe (provincias imperiales); y nos hemos referido a la más amplia y perpetua concesión que de él podía hacerse a los particulares, dando lugar a la que nosotros llamamos propiedad provincial, y que análogamente era llamada en Oriente, especialmente en Egipto, γῆ ἰδιόκτητος. Pero esta forma de concesión, en la que sólo la obligación de pagar el impuesto exteriorizaba el dominio eminente del Estado, era excepcional; los papiros greco-egipcios nos enseñan que la administración pública concedía como ἰδιόκτητος únicamente la tierra apta para jardín, viñas o frutales, como también las áreas edificables.

La tierra apta para la agricultura, en la cual radicaba la estimación que para el imperio romano representaba la posesión de Egipto, estaba en condición jurídica muy distinta; era arrendada a los "aldeanos del Estado", δημόσιοι (o también βασιλικὴ) γεωργοί por un término que no solía exceder de cinco años y con la obligación de pagar como tributo al Estado concedente una cuota del rédito neto. Pero la crisis económica que afligió al Imperio a partir de fines del siglo II d. C., hizo que la cuota no se calculase ya sobre el rédito efectivo, sino sobre un rédito hipotético previsto con excesivo optimismo; y la resistencia de los aldeanos contra este régimen de disfrute provocó medidas coercitivas, como la imposición de atender al cultivo y el consiguiente constreñimiento a no abandonar la propia aldea (ἰδία κώμη, o simplemente ἰδία), por malas que en ellas fueran las condiciones de vida.

Pero desde la época de CONSTANTINO en adelante, fueron surgiendo aquí y allí, entre la masa de los súbditos, ricas familias que se convirtieron, por su posición económica y política, en centros de atracción de la población de las aldeas circundantes; a su protección (*patrocinium*) se encomendaron, en efecto, los aldeanos y a cambio de la defensa que obtuvieron contra las pretensio-

nes más vejatorias de los funcionarios públicos, ofrecieron servicios y prestaciones en especie. Fué así como, en varias localidades, extensas zonas de terreno fueron tomadas en arrendamiento por las familias más conspicuas, por largo plazo o a perpetuidad, asegurando al Estado una entrada global y asignando luego al cultivo de las fracciones particulares a aldeanos subarrendatarios³.

De este modo surgieron, en el siglo iv d. C., dos tipos de concesión: *ius perpetuum*, que tuvo por principal objeto los *fundi rei privatae* (del fisco como tal), y *ius emphyteuticarium*, en el cual finalmente revivía el nombre de la antigua institución griega, y que tuvo por objeto los *fundi patrimoniales* (en propiedad de la dinastía reinante). Tanto el titular de *ius perpetuum* como el de *ius emphyteuticarium* pagaban un canon, pero mientras la concesión en *ius perpetuum* era irrevocable y no modificable en sus condiciones, los fundos enfiteuticarios estaban formalmente sujetos a la renovación periódica de la concesión. En la práctica, la licitación que se llevaba a cabo era por lo general de mera forma, y concluía con la adjudicación renovada en favor del precedente enfiteuta; sin embargo, de ella podía resultar un aumento del canon, y de todos modos importaba una ingerencia del Estado en los resultados del cultivo, ingerencia de la que el titular del derecho perpetuo quedaba inmune. Esto explica por qué a este titular, y sólo a él, le dan las fuentes del siglo iv el nombre de *dominus*.

En el siglo v las dos instituciones aparecen fundidas en una sola, bajo el nombre que ahora ha prevalecido de *ius emphyteuticarium*. Por la perpetuidad, y en consecuencia por la invariabilidad del canon, la concesión responde a los criterios del *ius perpetuum*; pero como residuo del régimen de la enfiteusis en sentido estricto, subsiste la vigilancia administrativa sobre el cultivo y sus resultados. La posición de concedente no era ya asumida solamente por el Estado, sino también por particulares; porque las grandes familias dispersas en las provincias habían llegado, ya a través de concesiones cada vez más amplias, ya mediante usurpaciones que la autoridad pública debilitada había debido consentir, a hacerse reconocer como titulares de vastos señoríos

³ El persistente vínculo de estos subarrendatarios al fundo es, como se ha visto más arriba (ps. 71 y ss.), la causa principal de la servidumbre de la gleba (colonato).

territoriales, en los cuales el contenido privatístico de la propiedad se integraba con elementos publicísticos que hacían de ellos una semisoberanía; así estos señores feudales se trasformaban de concesionarios en concedentes, de enfiteutas o utilistas (según la terminología que después prevaleció en la Edad media) en propietarios o titulares del dominio directo.

Y he aquí que se renueva la disputa sobre el carácter de la concesión, es decir, si debería ser concebida como locación o como venta. En los documentos continuaba empleándose promiscuamente la terminología de los dos contratos; y para algún caso análogo (concesión del goce de navíos por tiempo indeterminado) se había llegado a acuñar una palabra compuesta, que podemos traducir como *locación-venta* (μισθοπρασία). En el terreno práctico, la cuestión se concentró sobre el *periculum*, es decir, sobre la incidencia de los casos de fuerza mayor que destruyen el fundo o impiden el cultivo; construyendo la concesión como venta, el riesgo debería recaer sobre el concesionario, porque *casum sentit dominus*, y como comprador él sería el dueño; construyéndola como locación, el riesgo debería —en cambio— recaer sobre el concedente. Una constitución de ZENÓN, dictada alrededor del 480 d. C. (C. 4, 66, 1), resolvió el problema reconociendo al contrato enfiteutico una estructura propia, distinta de la de la venta y de la de la locación; el riesgo, salvo convención en contrario, se repartía en el sentido de que, si la fuerza mayor destruía el fundo (por ejemplo, en caso de sumersión), se perjudicaba el concedente (y cesaba la obligación de pagar el canon); en cambio, si producía daños temporarios y reparables (por ejemplo, sequía, falta de inundación del Nilo), se perjudicaba el concesionario (que continuaba pagando).

Sobre la enfiteusis, así definitivamente introducida en el sistema del derecho privado, tuvo que legislar también JUSTINIANO, en particular con respecto a los bienes de la Iglesia⁴. Para evitar que los enfiteutas aprovecharan de la poca vigilancia de las autori-

⁴ El cuantioso patrimonio que iglesias y monasterios se constituyeron desde la época de Constantino en adelante, había sido primero disfrutado directamente por medio de colonos (siervos de la gleba) y la enfiteusis había sido lisa y llanamente prohibida; pero la prohibición fué abolida por Justiniano, y documentos de esta época testimonian el uso de elegir como enfiteutas a personas eminentes y acaudaladas.

dades eclesiásticas, el emperador recurrió al fin originario de la institución, que consistía en someter fundos más o menos incultos a una explotación racional; no llegó a hacer del mejoramiento un deber jurídico, pero la obligación de no deteriorar el fundo fué concebida por él como esencial e inderogable, con la sanción de la devolución, es decir, de la vuelta del fundo al propietario. Sin embargo, continuaba difundiéndose en ciertos ambientes la idea de que se pudiese transferir contractualmente al enfiteuta la suma de los poderes sobre la cosa, y con ella el riesgo total, reduciendo casi la situación del concedente a la de acreedor del canon; un papiro del siglo VI nos presenta precisamente un contrato en el cual, en contraste con la legislación más reciente, el enfiteuta se reserva el derecho de mejorar o deteriorar el fundo a su agrado, y asume el riesgo de cualquier acontecimiento de fuerza mayor⁵.

El derecho justiniano impone al enfiteuta la obligación de denunciar al propietario toda transferencia del *ius emphyteuticarium*, y concede al propietario un derecho de prelación, es decir, la facultad de extinguir el *ius in re* pagando la misma suma ofrecida por el adquirente (*ius προτιμήσεως*); si no ejerce tal derecho, percibe una especie de tributo, el *laudemium*, equivalente al 2 % del precio pagado por el nuevo enfiteuta; la sanción aplicada en el caso de incumplimiento, como también si por tres años falta el pago del canon, es siempre la devolución en el sentido ya visto.

*

* *

A diferencia de la enfiteusis, la superficie es una institución puramente romana, que encuentra escasa correspondencia en otros derechos, tanto antiguos como modernos. Se vincula al principio *superficiis solo cedit*, en virtud del cual, como ya hemos señalado (p. 214), cualquier construcción sobre el suelo ajeno accede a la propiedad del terreno. Principio que no se explica, a su vez, sino como una exageración del criterio del absoluto señorío sobre la cosa, por el cual ella pertenece al propietario no sólo en su actual

⁵ Cfr. el documento publicado por J. MÁSPERO entre los *Papyrus grecs d'époque byzantine* del museo de El Cairo, III, n° 67299 (ahora en mis *Negotia*, n° 115); y sobre él ARANCIO-RUIZ, *Applicazione del diritto giustiniano in Egitto*, en "Aegyptus", I, 1919, ps. 21 y ss.

estructura y destino, sino en toda posibilidad aunque remota de disfrute del espacio aéreo y del subsuelo: *usque ad sidera et usque ad inferos*. Del principio deriva la exclusión de la división por planos horizontales, de modo que el suelo pertenezca a un propietario y el edificio a otro o que pertenezcan a diferentes propietarios los distintos pisos de una casa.

Pero el homenaje a este principio, formalmente mantenido hasta en el derecho justiniano, no podía evitar que surgiese en varias hipótesis la necesidad práctica de construcciones hechas sobre el suelo ajeno con el consentimiento del propietario y con la intención concorde de que fuese garantizada al constructor la mayor libertad de acción sobre el edificio.

También aquí la necesidad se hizo sentir primeramente para las construcciones sobre el suelo público. Solían, en efecto, los magistrados conceder a los particulares permiso para construir sobre el foro o sobre las calles *tabernae* (tiendas), con la inteligencia de que el suelo permaneciese público pero se le garantizase al constructor la disponibilidad de la tienda, comprendidas las facultades de destruirla y de transferirla a otros. Muy explícito, a este respecto, es D. 18, 1, 32: "*Qui tabernas argentarias vel ceteras, quae in solo publico sunt, vendit, non solum sed ius vendit: cum istae tabernae publicae sunt quarum usus ad privatos pertinet*"⁶. Cuál era el alcance del *usus* de que estamos tratando, y si en él se puede discernir un derecho real, es problema que quizá no fué resuelto tampoco por los juristas romanos; sobre todo es muy incierto si, aparte de la tutela administrativa frente al Estado concedente, correspondiese al concesionario también una acción contra el tercero que entrase en posesión de su *taberna*. De todos modos, cabe observar que no basta para excluir la posibilidad de tal protección el nombre, que aquí y allí vuelve, de locación-conducción; hemos visto ya usado el mismo nombre en los textos relativos al *ius in agro vectigali*, del que parece cierto que naciese una *actio in rem*; y, en general, no se insistirá nunca bastante en señalar que la terminología contractual, aplicada a concesiones de bienes públicos, tiene siempre un valor de mero parangón; la insuficiencia del contrato para fundar derechos reales no se ex-

⁶ Cfr. también, para otras concesiones de suelo público con fin edificatorio, mis *Negotia*, n.º 109 a 111; y para concesiones análogas en la Sicilia griega, ARANGIO-OLIVIERI, *Inscriptiones Graecae Siciliae*, etc., 1925, ps. 62 y ss.

tiende enteramente a las concesiones administrativas, que no son contratos aunque sean abusivamente llamadas con los nombres de los negocios de contenido más afín.

Entre los particulares, en cambio, la concesión de edificar sobre el suelo ajeno, o la cesión del goce del edificio sin transferir la propiedad del suelo, tienen lugar por contrato propiamente dicho; y aquí debía aplicarse en todo su rigor el conocido principio de la insuficiencia de él para la constitución de derechos reales. En consecuencia, la concesión de edificar (o de gozar del edificio construido) no pudo concebirse sino como locación-conducción del suelo, eventualmente unida a una cesión definitiva del goce del edificio en forma de compraventa; el efecto era vincular, uno frente a otro, al propietario del suelo y al llamado *superficiario*, y con ellos a sus herederos, pero sin la posibilidad de que la relación jurídica continuase entre los sucesores a título particular. Para evitar las consecuencias de esta limitación era necesario que al transmitir, por ejemplo, el suelo a un tercero, el propietario gravado exigiese la promesa de respetar el goce del superficiario; análogamente, si era éste quien transmitía a otro superficiario su goce, debía comprometerse a hacerlo respetar por el *dominus*. Así, cada contrato vinculaba, como es natural, solamente a los contratantes; pero éstos, si eran llamados a juicio, estaban obligados a ceder la acción (*conducti* o *empti*) que, a su vez, tenían contra el tercero. Tal la enseñanza que se extrae de la parte genuina de D. 43, 18, 1, § 1⁷. Un nuevo paso en favor del superficiario lo dió el pretor al concederle, contra todo tercero, la protección interdictal del ejercicio de su derecho (véase *infra*, p. 311). Pero cuando, en el principio del fragmento citado, encontramos agregada a la cláusula interdictal la frase "si qua alia actio de superficie postulabitur, causa cognita dabo", y cuando en los párrafos sucesivos encontramos explicada esta frase como alusiva a una acción real, construida sobre el modelo de la *rei vindictio* y correspondiente al superficiario contra el *dominus soli* y contra cualquier tercero, es inevitable el reconocimiento de la interpolación:

1) porque, después de haber dado el esquema del *interdictum* (el cual, como sabemos [ps. 158 y ss.], no es una acción), no po-

⁷ Considero interpolada en este párrafo solamente la parte que lo cierra *sed longe-polliceri*. La exposición que he hecho de las partes restantes me dispensa de defender su genuinidad, contra los ataques parciales de ALBERTARIO y la crítica radical de BESELER.

día el pretor hablar de "*alia actio*"; sólo el derecho justiniano tiende a concebir los interdictos como acciones (p. 176);

2) porque toda la regulación de la institución sobre la base de las acciones *conducti* y *empti*, tal como la hemos descrito, es incompatible con la existencia contemporánea de una acción real;

3) porque en el sistema del Edicto pretorio se observa rigurosamente la separación entre las fórmulas de las acciones, por una parte, y los interdictos, por la otra; en particular, las acciones *in rem*, desde la *hereditatis petitio* hasta la *vindicatio usus fructus* y *servitutis* están todas agrupadas al principio de la *pars de iudiciis* (cfr. en el Digesto, del título v, 3, al título viii, 5), mientras los interdictos están en un apéndice (D., libro xliii). Es, pues, absolutamente extraño el caso de una *actio in rem* prometida en un inciso abandonado de la *pars de interdictis*.

En la época clásica, pues, el proceso de transformación de la obligación que tiene por objeto una *superficies* en el derecho real del mismo nombre, es apenas iniciado con las fatigosas adaptaciones de las acciones contractuales y con la concesión del interdicto de *superficiebus*; la consagración del nuevo derecho real es justiniana, aunque probablemente precedida por el trabajo para nosotros no controlable, de la jurisprudencia posclásica. Más que la imitación de cuanto quizá los clásicos ya habían admitido para las concesiones de suelo público a los fines de la construcción de tiendas, debieron conducir a estos resultados los dos motivos más característicos de las reformas justinianas en el campo de los *iura in re*: la pérdida conciencia de la antítesis entre el contrato como fuente de obligación y el acto constitutivo de derecho real, y la contaminación del derecho imperial con el de las provincias helenísticas. El cual, en el punto que ahora nos interesa, no conocía absolutamente el principio *superficies solo cedit*, y no veía ningún obstáculo para admitir la división de la propiedad inmobiliaria por planos horizontales. Si no se renegó formalmente del viejo principio, y el derecho de superficie fué más bien clasificado entre los *iura in re aliena*, esto derivó todavía una vez más de ese carácter de compromiso entre lo viejo y lo nuevo, entre lo romano y lo oriental, que hemos visto ser propio del derecho justiniano.

El superficiario paga al *dominus soli* un canon anual, que toma el nombre de *solarium*. En el derecho justiniano corresponden

a él y contra él, en los límites de su interés y de su responsabilidad, todos los medios que normalmente corresponden a los propietarios y contra ellos, en razón de las relaciones de vecindad (acciones confesorias y negatorias, *actio aquae pluviae arcendae*, *cautio damni infecti*, etc.), y en los mismos límites se le consiente la constitución de servidumbres sobre o en favor del edificio: todo esto era desconocido para el derecho clásico⁸.

FRANJA MORADA

⁸ Sobre el desarrollo del derecho de superficie cfr. especialmente BAVIERA, *Scritti giuridici*, I (1909), ps. 177 y ss.; ALBERTARIO, *Il pegno della superficie*, Pavia, 1911 (*Studi cit.*, 2, ps. 457 y ss.), e *Il possesso del superficario*, Pavia, 1912 (allí, ps. 409 y ss.). De acuerdo con ellos, aunque mucho más (y demasiado) radical en la crítica de los textos, BESELER, *Contributi*, I, ps. 100 y ss. Por la claridad de la *a. in rem* se pronuncian, pero con argumentos que no parecen persuasivos, RICCOBONO, *Dal dir. rom. class. etc.*, p. 510; y BRONDI, *Categoria cit.*, ps. 501 y ss.

Sobre la superficie en el derecho justinianeo véase PUGLIESE, *Studi dedicati alla memoria di G. Segrè* ("Temi Emiliana", 20, 1943, n° 4), ps. 119 y ss.

CAPÍTULO X

DERECHOS REALES DE GARANTÍA: PRENDA E HIPOTECA

Una deuda puede garantizarse de diversos modos, los cuales se reducen todos a dos ideas fundamentales: o que un tercero asuma la responsabilidad por la falta de cumplimiento (garantía personal), o que quede reservada a disposición del acreedor una cosa sobre la cual él pueda satisfacerse en caso de incumplimiento (garantía real). En los casos de esta última categoría, los romanos hablan, con expresión figurada pero eficacísima, de *obligatio rei*, de *res obligata*. De las garantías personales se tratará en la parte de las obligaciones (cap. XVIII, § 3); aquí nos interesa solamente la segunda categoría, en cuanto algunos modos de garantía se traducen en tipos particulares de derechos reales.

Esto no ocurre en la más antigua garantía, la *fiducia*. Hemos visto, al tratar de la *mancipatio* (p. 223), que se podía transmitir la propiedad de una cosa con el acuerdo explícito de que cuando el vendedor estuviese dispuesto a restituir el precio, debiese el comprador conformarse con remanciparla. Esta especie de acuerdo solía tener lugar, fuera de varios casos sobre los cuales no corresponde insistir en este lugar (*fiducia cum amico*), también con fines de crédito (*f. cum creditore*): el precio de la primera *mancipatio* tenía función económica de dación en mutuo, el de la segunda tenía función de restitución, y la cosa, que pasaba sucesivamente de uno a otro y viceversa, tenía función de garantía. Pero desde el punto de vista de los derechos reales no surge aquí una figura nueva: el derecho que el acreedor adquiere es siempre *dominium ex iure Quiritium*. Y las cosas no cambian siquiera cuando, por la transformación de la *mancipatio* en *imaginaria*

venditio, dación de la suma en mutuo y dación de la cosa en garantía, se escinden en dos negocios jurídicos distintos.

Pero ya desde época muy antigua debió estar difundido respecto de las cosas *nec Mancipi*, aunque no protegido por acción judicial, un tipo más ágil de garantía real, consistente en la transferencia de la simple disposición de hecho de la cosa: el *pignus*, correspondiente al ἐνέχυρον de los griegos. Para la época más antigua, las fuentes conservan su nombre sólo en el campo del proceso, a propósito de aquella *legis actio* que se denomina precisamente *per pignoris capionem*, y que consiste en la toma de posesión de objetos del deudor para satisfacción de determinados créditos (p. 135); y muy poco sabemos del procedimiento subsiguiente para que esta institución pueda iluminar el primitivo régimen de la prenda. Ciertamente es que el reconocimiento de la prenda como garantía voluntariamente asumida mediante la entrega de una cosa mueble, *Mancipi* o *nec Mancipi*, se tuvo por primera vez en el Edicto del pretor, hacia el fin de la República; al deudor que cumplía, o a cualquier otro que en su lugar hubiese entregado la cosa en prenda, se le otorgó una acción para obtener su restitución cuando la obligación garantizada estuviese extinguida, y, durante el tiempo en que la prenda se hallaba en poder del acreedor, se le reconoció a éste la posesión interdictal (cfr. ps. 303 y ss.), mientras la propiedad (o la posesión *ad usucapionem*) la conservaba el pignorante.

Poco más tarde se admitió que el *pignus* se pudiese constituir también mediante simple *conventio*, sin la transmisión material de la cosa, y el nuevo sistema se aplicó ampliamente a los inmuebles. Es incierto de qué modo se introdujo este tipo de garantía, pero la comparación con la evolución jurídica griega, como también varias referencias de nuestras fuentes romanas, muestran que la institución ha derivado del uso que regía en materia de *fiducia*, de conceder al deudor mismo, a título precario, el goce y disfrute de la cosa mancipada; eliminada con el uso de la prenda la necesidad primordial de que el acreedor se hiciese inmediatamente propietario de la cosa entregada en garantía, quedó la idea de que una cosa pudiese ser reservada a la eventual ejecución del acreedor, aun permaneciendo en el intervalo no sólo en propiedad sino también en posesión del deudor o de cualquier otro que la hubiese ofrecido en su lugar. Con el nombre de *pignus conven-*

tum, se usó también el griego de *hypotheca* (ὑποθήκη); pero este último parece haber entrado muy tarde en el uso de los juristas, y no haber gozado de mucho favor entre ellos¹.

El primer caso de conventio pignoris protegido por el Edicto pretorio fué el de los instrumentos y animales introducidos en el fundo por el locatario (*invecta et illata*) y considerados como garantía del locador por el crédito del alquiler. Primero un *interdictum salvianum* permitió al locador tomar posesión de las cosas mismas en caso de incumplimiento, siempre que se hallaran aún en poder del locatario; posteriormente una *actio serviana* le permitió ocuparlos aunque hubiesen pasado a la posesión, y aun a propiedad, de terceros. Esta acción serviana parece haber sido extendida, antes de la redacción juliana del Edicto perpetuo, y con las oportunas adaptaciones, al *pignus conventum*; la acción se concede contra cualquier poseedor, salvo que en la fórmula—cuya estructura es, por lo demás, bastante incierta— se debía hacer explícita mención del ya verificado incumplimiento. La misma acción puede intentarse, siempre que se haya verificado el incumplimiento de la obligación, también por el acreedor pignoraticio que haya perdido la posesión de la cosa; mientras que para el tiempo anterior al vencimiento, por lo menos en derecho clásico, parece que no tuviese otro remedio que los interdictos posesorios (cfr. ps. 305 y ss.).

¹ La tesis de la interpolación justiniana de todos los textos que nombran la *hypotheca* fué sostenida por M. FEHR, *Beiträge zur Lehre vom römischen Pfandrecht in der klass. Zeit* [Contribuciones a la doctrina del derecho romano de hipoteca en la época clásica], Upsala, 1910, con exégesis sugestiva. La oposición de ERMAN (*Pignus hypothecave*, en *Mélanges Girard*, I, ps. 149 y ss.) y de MANIGK (voz *Hypotheca*, en la *Enciclopedia de la antigüedad clásica* de PAULY y WISSOWA) pareció justificada en este sentido: que mientras una revisión de la terminología por parte de los comisarios justinianos se habría actuado uniformemente en los textos de los diversos juristas, el nombre *hypotheca* es también en los Digestos rarísimo entre la mayoría de los jurisconsultos, y es en cambio muy usado en los pasajes extraídos de las obras de Gayo y de Marciano que se titulan precisamente *ad formulam hypothecariam*. ¿Y cómo nunca los jurisconsultos habrían cambiado el título de estas obras dándoles por añadidura un nombre que, recordando la fórmula, parecía referirse al proceso clásico? EHRARD (*Die Digestenfragmente "ad formulam hypothecariam" und die Hypothekenzereption* [Los fragmentos de los Digestos "ad formulam hypothecariam" y la recepción de la hipoteca], Leipzig, 1917) ha tentado resolver el problema atribuyendo a la jurisprudencia posclásica una reelaboración de las obras de Gayo y de Marciano; la cosa no es improbable, aun cuando sea difícil la demostración plena de semejante tesis.

Como consecuencia de la creación de la *actio quasi serviana* (llamada también *hypothecaria* o *pignoratitia in rem*), la prenda y la hipoteca entraron a formar parte de la categoría de los derechos reales. Ellos se distinguen de los otros *iura in re aliena* en que mientras servidumbre, usufructo, enfiteusis, superficie, importan un goce actual de la cosa por parte del titular o una limitación actual del goce del propietario, la prenda y la hipoteca miran hacia el valor de cambio de la cosa, por la parte capaz de sustituir la satisfacción que el acreedor espera del puntual cobro del crédito; sin embargo, si hay, a veces, una ventaja actual del acreedor, como en el caso de prenda de una cosa fructífera, este goce es un accesorio respecto a la estructura fundamental de la relación. Entre *res serviens* y *res obligata* hay, en suma, la misma diferencia que existe entre un esclavo y un deudor que en caso de insolvencia puede ser reducido a esclavitud: una está sujeta en acto, la otra en potencia.

La realización del derecho del acreedor pignoraticio o hipotecario puede ser, en tesis general, concebida de dos modos diversos: la historia del derecho conoce, en efecto, sistemas en los cuales al incumplimiento de la obligación sigue la caída de la cosa en propiedad del acreedor insatisfecho, y sistemas en los cuales al acreedor sólo le corresponde el derecho de venderla, quedándose con la parte del precio que cubra el valor del crédito con los respectivos intereses y gastos, y restituyendo al propietario el excedente. En el mundo griego, por ejemplo, es cierto que ha prevalecido por mucho tiempo el primer tipo de satisfacción del acreedor, mientras que el segundo se ha practicado muy tarde.

Probablemente, también en Roma prevaleció en los orígenes el primer tipo. Conduce a esta conclusión la estructura primitiva de la *fiducia*, en cuyo origen el acreedor, que se hacía propietario desde el momento en que la cosa le había sido dada en garantía, quedaba definitivamente en esa condición si el deudor no la rescataba en tiempo. Pero ni siquiera para la *datio* y para la *conventio pignoris* faltan los vestigios de una concepción semejante. En efecto, también los textos de la edad imperial que los estudiosos han depurado de las superposiciones posclásicas, muestran que las partes tenían la posibilidad de elegir entre los dos regímenes de la *lex commissoria*, que importaba la caída de la cosa en propiedad del acreedor pignoraticio, y del *ius distrahendi*, sobre cuya base el acreedor podía vender la cosa pignorada o dada en *fiducia* o

hipotecada, sea que estuviese ya en posesión de ella, sea que debiese hacérsela entregar por el poseedor, buenamente o con la *actio quasi Serviana*. Solamente en tiempo de los Severos, según parece, el *ius distrahendi* se entiende como querido por las partes toda vez que éstas no hayan expresado la voluntad opuesta; posteriormente Constantino prohíbe la ley comisorio, y hace del *ius distrahendi* un elemento esencial de la prenda².

Pero no de manera que no subsista aún en el derecho justinianeo algún rastro de la antigua concepción. Si no se presenta ningún comprador, el acreedor puede pedir al emperador la atribución de la propiedad de la cosa (*impetratio dominii*), la cual, sin embargo, no le puede ser concedida sino bajo la condición de la falta de rescate por parte del expropiado dentro de los dos años; y parece que en el acto de constitución de la prenda o hipoteca se pudiese pactar que vencido cierto término después del fijado para el cumplimiento, el acreedor estaría autorizado para adquirir él mismo, a su justo precio, la cosa pignorada.

Tanto en este último caso como después del ejercicio del *ius distrahendi*, se puede tener un excedente del valor de la cosa sobre el monto del crédito garantizado; tal excedente, que tiene también un nombre griego, *hyperocha* (ὑπεροχή), es restituído al pignorante (o fiduciante, o propietario de la cosa gravada con hipoteca).

En cuanto a la posición recíproca de las partes antes de que se verifique el incumplimiento, es diversa según que se trate de prenda propiamente dicha o de hipoteca. En el primer caso, como se ha visto, la posesión pasa al acreedor, y con la posesión pasa, cuando la cosa sea fructífera, el derecho de percibir los frutos, los que se imputan a los intereses y, cuando sea superada la tasa convencional o legal de éstos, al capital (ἀντίχρησις)³; el hecho de que el constituyente conserve la propiedad (o eventualmente la *possessio ad usucapionem*) hace que sean válidos los actos de disposición por él realizados.

² Cfr. NABER, *De lege commissoria*, en "Mnemosyne", 32, 1904, ps. 81 y ss.

³ A propósito cfr. MANIGK, *Gläubigerbefriedigung durch Nutzung* [Satisfacción del acreedor mediante el goce], Berlin, 1910. Es su mérito haber demostrado cómo, para actuar la anticresis, no fuese necesario un pacto expreso.

El mismo fenómeno se produce, en forma todavía más típica, respecto de la hipoteca, en la cual las transferencias de la propiedad y de la posesión se cumplen sin estorbos y el goce le queda al hipotecante hasta el momento en que, verificándose el incumplimiento, el acreedor hipotecario ejerza su derecho.

Esta última característica de la hipoteca hace para nosotros inseparable de la institución la exigencia de la publicidad; mientras son raras, en efecto, las hipótesis en que la existencia de un derecho real ajeno de goce permanece por mucho tiempo ignorada al adquirente de la propiedad, el derecho del acreedor hipotecario puede permanecer latente por tiempo indeterminado, donde no se hayan predisposto medios idóneos para hacer conocer su existencia a los interesados. Entre los sistemas que la antigüedad nos ofrece de tal publicidad, deben mencionarse especialmente los *ἄγοι* de la Grecia clásica: piedras que se colocaban en los límites de los fundos, inscribiendo en ellas la mención de la hipoteca y el nombre del acreedor. Pero también en esta parte, como en general en todo el régimen de la propiedad inmobiliaria, el derecho romano no presenta una organización de publicidad; cosa difícilmente explicable de otra manera que con la repugnancia de la jurisprudencia romana hacia toda forma de documentación *ad sollemnitatem*. En la edad posclásica se proveyó precisamente a una mayor publicidad mediante el documento: en una constitución del emperador León (C. 8, 17, 11, año 472 d. C.), se consideró privilegiado el *pignus publicum*, constituido mediante declaración trascrita en las actas de un magistrado (*apud gesta*); e interpolando la misma constitución, los compiladores de JUSTINIANO admitieron también un *pignus quasi publicum*, constituido con documento suscrito por tres testigos de óptima fama; desprovisto de estas formas, el *pignus privatum* debió aplicarse sólo como prenda manual de cosas muebles.

La negligencia de la jurisprudencia clásica frente a la institución de la hipoteca, resulta cierta también en lo que se refiere a los modos de constitución. No sólo prenda e hipoteca se constituyen por convención, contra la regla de los derechos reales, sino que, mientras para la constitución de la prenda manual se halla organizado un tipo de contrato de líneas bien definidas y de presupuestos precisos, el *pactum hypothecae* (o *conventio pignoris*) parece abandonado al arbitrio de las partes. La hipoteca se puede, ade-

más, constituir por legado. De la prenda constituida por disposición del magistrado y de las hipotecas legales, especiales y generales, se trata en otras partes (cfr. p. 173, y más adelante en materia de dote y de tutela).

Solamente las cosas corporales pueden ser objeto de la prenda y de la hipoteca como derechos reales; aunque el derecho clásico haya admitido que se pudiese constituir hipoteca por parte del titular de *ius in agro vectigali* y de propiedad pretoria, objeto de la prenda no fué considerado ni el *ius in agro vectigali* ni la propiedad pretoria como cosa incorporal, sino la cosa corporal que era su objeto, en los límites del derecho del constituyente. Los clásicos no admitieron, en cambio, derecho de prenda sobre el usufructo o las servidumbres o la superficie; los justinianos lo admiten, y desde el punto de vista dogmático tienden a considerar objeto de la prenda el derecho real mismo, entendido como cosa incorporal. En cuanto a la prenda del crédito (*pignus nominis*) y a la prenda de la prenda (*subpignus*), es claro que no son derechos reales; son formas de cesión parcial o condicional del crédito o del derecho de prenda, que tienden a alcanzar un resultado económico análogo al que se obtiene cuando se dan en prenda cosas corporales.

Las causas de extinción de la prenda se vinculan en parte a su naturaleza de derecho real, en parte a su función de garantía. A la primera serie de causas pertenecen: la destrucción de la cosa; la confusión, es decir, la coincidencia de las cualidades de propietario y de titular de la prenda en la misma persona; la transmisión que el acreedor haga de la cosa al tercer adquirente en ejercicio del *ius distrahendi*; la verificación de la *lex commissoria*; la renuncia del titular; la prescripción adquisitiva de la cosa, cumplida en provecho de un adquirente de buena fe. A la segunda serie pertenecen —según parece— todos los modos de extinción de la obligación, salvo alguno que la extingue formalmente, pero transfiriendo todo su contenido económico a una obligación nueva, como es el caso de la *litis contestatio*; hay que recordar, sin embargo, la reforma del emperador Gordiano en virtud de la cual el titular de varios créditos contra el mismo deudor, garantizados algunos con prenda y otros no, puede, mediante el empleo de la *exceptio doli*, conservar la prenda aun después de que los primeros

hayan sido pagados y hasta la extinción del último (*pignus Gordianum*)⁴.

Sobre una misma cosa pueden concurrir varios derechos de hipoteca. Se aplica en este caso el principio *prior tempore potior iure* que importa, por lo menos hasta el principio de la época clásica, que la prenda subsiguiente esté condicionada a la extinción de la anterior, mientras que en edad más avanzada (no es fácil establecer cuándo) se admitió que valiese incondicionalmente, salvo que el segundo (tercero, etc.) acreedor pudiese cobrarse solamente con lo que quedara del valor de la cosa después de la satisfacción del primero. El acreedor de grado ulterior puede satisfacer a cualquiera entre los precedentes y sucederle en su posición de prioridad, aun postergando a los acreedores intermedios; esta subrogación se verifica aunque el acreedor preferente rehuse aceptar la suma que a este fin se le ofrece. La regla *prior tempore etc.*, sufre excepciones, en las cuales la preferencia está determinada por criterios diversos; así, el *pignus publicum* o *quasi publicum* prevalece sobre el *privatum*, y otras hipotecas son diversamente privilegiadas (así las que existen en favor del fisco por las deudas de impuestos, de la mujer por la restitución de la dote, etc.).

⁴ Sobre el tema, NARDI, *Ritenzione e pegno Gordiano*, Milano, 1939: cfr. el papiro del museo de Berlín (BGU., III, 741) nuevamente publicado por mí en el n° 119 de los *Negotia*, y las notas relativas.

CAPÍTULO XI

LA POSESIÓN Y LA CUASI POSESIÓN

§ 1. EL FUNDAMENTO DE LA PROTECCIÓN DE LA POSESIÓN

Possessio y *possidere* expresan, según la mejor etimología¹, el actuar sobre una cosa como señor de ella: posesión es, pues, el señorío ejercido por alguien sobre una cosa, cuando se lo valora en sí mismo, independientemente de que sea o no conforme al derecho. La situación, en sus presupuestos y en su actualidad, es de mero hecho, en cuanto el derecho objetivo, mientras dispone los medios idóneos para la adquisición de los derechos sobre las cosas, no los dispone para la posesión; sin embargo, el ordenamiento jurídico protege tal situación contra quienquiera que no pueda oponer al poseedor un derecho propio sobre la cosa o no pueda demostrar que ha sufrido de él un daño con relación a ella. No derecho subjetivo, pues, sino estado o hecho jurídico continuativo, presupuesto de la aplicación de normas de derecho.

Cada uno de nosotros, en tiempos de civilización avanzada, siente que vive en un mundo que tiene forma jurídica, y, por lo que más propiamente se refiere a los objetos del mundo externo, siente que todos aquellos que ofrecen utilidad, tienen también normalmente un dueño a quien esta utilidad aprovecha; caminando a lo largo de un fundo, por inculto que sea, o encontrando un animal de matadero o de trabajo, por desbandado que esté, no se nos ocurre considerarlos nunca como *res nullius* libremente ocupables, sino que nos imaginamos siempre la figura de un dueño.

¹ Que las hace derivar del verbo *sedere* y del sufijo *pot*, raíz de *po(t)-se*, de *pot-estas*, de *pat-er*; cfr. BONFANTE, *Il punto di partenza nella teoria romana del possesso*, en *Scr. giur.*, III, ps. 516 y ss.

Pero no siempre podemos afirmar con pleno conocimiento de causa, que de tal cosa es propietario Ticio, de tal otra Cayo; para que semejante afirmación sea fundada, es necesario que tengamos conocimiento del hecho o acto sobre cuya base Ticio o Cayo la ha adquirido, y de todos los trasposos sufridos por la cosa antes de llegar a él, por lo menos desde el momento en que otro la poseyó por el tiempo necesario para la adquisición por usucapión o prescripción (cfr. p. 230). A la persuasión sobre el derecho de otro se sustituye por eso, en la práctica, la presunción que nace del hecho; al respeto por la facultad de otro para disponer de la cosa, se sustituye el respeto por la disposición que otro tiene visiblemente de ella. Se considera como dueño del reloj a quien normalmente lo lleva en el bolsillo, como dueño del fundo a quien normalmente lo cultiva por sí o lo da en arrendamiento o aparcería (no ya al bañero o al posadero que tiene en depósito, entre tantas cosas preciosas, también un reloj; no ya a aquel que sabemos o imaginamos haber tomado el fundo de otro para cultivarlo como arrendatario o aparcerero). En suma, nuestra persuasión de vivir en un mundo jurídicamente ordenado se resuelve necesariamente en el respeto de las innumerables relaciones de posesión que vemos realizadas.

Allanándonos a respetar la posesión, nos acostumbramos también a ver, en todo cambio del actual estado de posesión, una turbación del orden vigente, tal que no se puede consentir sino en cuanto encuentre en el derecho objetivo su justificación. Mientras no soñamos siquiera en preguntar a quien tiene un reloj en el bolsillo cómo lo posee, pretendemos, en cambio, que nos dé una justificación quien pretende llevárselo. No bastará decir, por ejemplo, y demostrar, que el actual poseedor no lo ha adquirido legítimamente, porque la eventual injusticia del poseedor no sería corregida sino agravada cuando se iniciase una nueva posesión tan injusta como la anterior. Sólo entonces consideramos justa la pretensión del no poseedor, cuando tiende a eliminar la injusticia de la posesión actual, como sucede si Ticio, propietario, reivindica de Cayo la cosa que éste ha comprado a un tercero, o si Mevio, robado, demanda a Sempronio, ladrón, la restitución de la cosa robada.

A paridad de derecho, pues (o mejor de no derecho), la protección de la posesión es una exigencia fundamental. Exigencia de la cual no se da una explicación suficiente cuando se considera

que la posesión sea tutelada como imagen o posición avanzada de la propiedad, según la conocida doctrina de IHERING, porque, si así fuese, la tutela debería cesar y la cosa quedar expuesta a la ingerencia de cualquier otro cuando, como quiera que sea, se demostrase que el actual poseedor no es su propietario. Mucho más fundada es la doctrina de SAVIGNY, según la cual la tutela de la posesión es tutela de la paz social; entre varias personas que se disputan la disposición material de una cosa, el ordenamiento jurídico no podría permanecer neutral sin autorizar una lucha en la que solamente prevalecería la fuerza física; excluida esta solución, y puesto que no siempre hay entre los contendientes quien pueda invocar en apoyo de su pretensión razones de derecho, sólo queda tutelar la posesión como tal².

Si esto vale, en el mundo civilizado, para todos los tiempos y en todos los lugares, la aplicación práctica del principio varía de tiempo en tiempo y de lugar a lugar; sobre todo porque se acostumbra, para establecer dónde existe y dónde falta la posesión, cuándo se pierde y cuándo se conserva, vincular la valoración social del hecho de estar o no estar una cosa a disposición de persona determinada, con la justificación ético-jurídica de esta situación. Haber distinguido netamente los dos puntos de vista, con una visión exacta y lúcida de los datos de la experiencia, es uno de los más altos títulos de gloria de la jurisprudencia clásica; la perturbación que las nociones, y con ellas la regulación jurídica, sufren en la época justiniana, es la piedra de toque de la inclinación que el pensamiento jurídico ha sufrido por la confluencia de las más variadas corrientes de sentimientos y de ideas, malamente entendidas y asimiladas.

§ 2. LA POSESIÓN Y SU PROTECCIÓN EN DERECHO ROMANO

Hemos dicho que la distinción neta entre propiedad y posesión es propia del derecho evolucionado; en la costumbre primi-

² Esto sirve como crítica a los estudios de IHERING, *Der Grund des Besitzschutzes* [El fundamento de la protección de la posesión], en los "Jahrbücher für die Dogmatik" ["Anales para la Dogmática"], 9, 1868, ps. 1 y ss., y *Der Besitzwille* [El "animus possidendi"], 1889. Del libro de SAVIGNY, *Das Recht der Besitzes* [El derecho de la posesión], publicado

tiva, a la tendencia social de presumir una base de derecho en la posesión ajena, no se contraponen una especulación jurídica capaz de separar los dos puntos de vista. Es precisamente esta consideración la que hace, aun para nosotros, muy difícil la construcción jurídica de las antiguas *possessiones patricias* (cfr. ps. 204 y ss.) e incierto el régimen de la *l. a. sacramenti in rem* (cfr. p. 131, n. 9). La duplicidad del proceso, consistente en una *vindicatio* y una *contravindicatio* iguales y contrarias, y la intervención de la autoridad ciudadana que ordena a ambas partes dejar la cosa controvertida, llevarían a concluir que no se le reconoce entonces a la posesión ninguna eficacia; pero, cuando el proceso así planteado remata en una apuesta, y el juez de ésta es invitado a decidir cuál entre los dos contendientes está en lo justo, la reflexión sobre las exigencias a que el proceso responde, integrada con observaciones de derecho comparado, conduce a la persuasión de que el árbitro debiese en todo caso dar la causa por ganada a una de las partes; en consecuencia, si ninguna de las dos llegaba a demostrar la legitimidad de la adquisición, a aquella que tenía el más fuerte estado de posesión. Por otra parte, esa orden autoritaria de dejar la cosa controvertida, que originariamente debió traducirse en su conservación *apud iudicem* hasta la decisión de la controversia, queda en la época histórica como un mero residuo frente a la práctica establecida de asignar a uno de los litigantes la posesión interina (*vindiciae*), lo que se hacía ciertamente sobre la base de la opinión de los vecinos e integrantes de la familia; esto debía conducir insensiblemente a los árbitros a ser más exigentes con respecto al no poseedor que con respecto al poseedor interino, y a considerar como vencedor en la causa a éste, toda vez que aquél no llegase a probar su derecho preferente. Con esto se iba preparando la transformación que la *rei vindicatio* sufrió en la época del procedimiento formulario, cuando la posesión de la cosa dió derecho a la posición de demandado, y sólo al no poseedor (actor) le fué impuesta la carga de la prueba. Se hizo entonces particularmente importante establecer, en los casos en que la conciencia social no daba una respuesta segura, cuál entre los dos aspirantes

por primera vez en 1803, la última edición, dirigida por RUDORFF, es de 1865. De la infinita literatura dogmática sobre la posesión séame permitido recordar solamente estas dos obras; algunos escritos de carácter histórico y técnico serán recordados más adelante.

fuese el poseedor de la cosa; y así también mantener en posesión a quien hubiese sido turbado por ingerencias extrañas, y restablecer en la posesión, independientemente de cualquier investigación sobre la propiedad, a quien hubiese sido privado de ella mediante la actividad ajena turbadora de la paz social. Surgen así los *interdicta retinendae* y *recuperandae possessionis*, y con ellos la *possessio* propiamente dicha, o *possessio ad interdicta*.

La jurisprudencia romana reconoce esta posesión en quienquiera que se comporta como dueño con relación a una cosa; ello significa, desde el punto de vista material, la disponibilidad de la cosa (*corpore possidere*), y desde el punto de vista intencional (*animus*) la voluntad de conservarla y defenderla. Posee no sólo quien ha adquirido de buena fe, aunque no sea del propietario, sino también quien en las mismas condiciones ha adquirido de mala fe; no sólo el titular de un *ius in agro vectigali*, o quien se cree tal, sino también el ladrón o el asaltante. No posee, en cambio, normalmente, quien tiene la cosa en virtud de un contrato que lo vincula con quien se la ha entregado, ni el titular de un *ius in re aliena*: en estos casos se dice que el detentor tiene una simple *possessio naturalis*, o que posee en nombre de otro, presta servicio a la posesión ajena (*alienae possessioni praestat ministerium*). Tal es el caso del arrendatario, del depositario, del comodatario, del usufructuario o usuario; podrían comenzar a poseer solamente cuando, dejando de cumplir con las obligaciones contraídas, llegasen a tener la cosa en nombre propio, pero también a este resultado parece obstar la máxima *nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest*.

Sin embargo, hay casos en los cuales, aun subsistiendo un vínculo obligatorio entre quien retiene la cosa y el precedente poseedor, el derecho romano reconoce excepcionalmente al primero la posesión. Así sucede, como se ha visto, con el acreedor pignoraticio; así con el secuestratario, en poder del cual las partes depositan la cosa litigiosa para que sea devuelta al vencedor; así con el precarista, que ha obtenido la cosa del poseedor con la facultad de gozar de ella, pero con la obligación de restituirla a su requerimiento. La razón de estas situaciones privilegiadas es diversa. La posesión del secuestratario es consecuencia del hecho de que, entregándole la cosa, los litigantes han declinado toda pretensión relativa a la posesión interina. Para el acreedor pignoraticio, el reconocimiento

de la posesión es un residuo del régimen en virtud del cual, en caso de incumplimiento de la obligación, él adquiere la propiedad de la prenda; por otra parte, más se retrocede en la antigüedad y más la deuda contraída con garantía prendaria se presenta como un recurso extremo, y no parecía oportuno confiar la defensa de la cosa a quien había casi perdido la esperanza de volver a tenerla para sí. En fin, la posesión a título precario estaba antiguamente muy difundida como concesión de *ager publicus* por parte de las gentes patricias a sus clientes; el precarista permanecía la mayor parte de las veces sin turbación en el goce concedido, y era natural que, aun cuando el concedente pudiera por derecho revocar la concesión en cualquier momento, se dejase, sin embargo, al concesionario la carga de defender la posesión contra los terceros³.

Para defensa de la posesión están propuestos en el Edicto pretorio, como ya se ha indicado, los interdictos *retinendae* y *recuperaendae possessionis* (cfr. para el procedimiento, ps. 158 y ss.).

Los interdictos *retinendae possessionis* se aplican cuando el poseedor haya sufrido o tenga razón para temer molestias o turbaciones; y tienen formas y presupuestos algo diferentes según que se trate de cosas inmuebles o muebles. Para las primeras sirve el *int. uti possidetis*: "*Uti eas aedes, quibus de agitur, nec vi nec clam nec precario alter ab altero possidetis, quominus ita possideatis, vim fieri veto*" (D. 43, 17, 1 pr.).

Para las segundas el *int. utrubi*: "*Utrubi hic homo, quo de agitur, maiore parte huiusce anni fuit, quominus is eum ducat, vim fieri veto*" (D. 43, 31, 1 pr.)⁴.

Como se ve, mientras para los inmuebles se protege la posesión actual ("*uti... possidetis*"), para los muebles prevalece, entre los dos contendientes, el que ha poseído por más tiempo durante el último año; lo que no quiere decir que para vencer sea necesario haber poseído seis meses y un día, sino que implica una comparación entre las duraciones respectivas de las posesiones de los adversarios, excluido todo cómputo del tiempo en que la cosa ha permanecido en poder de terceros. Se admitió, sin embargo, que se

³ Sobre la función que estos casos podrían haber tenido en la evolución general de la posesión, cfr. Bozza, "*Annali Univ. Macerata*", 6, 1930, 213 y ss.

⁴ Entiéndase: se prohíbe a cualquiera impedir que quien en el último año ha poseído el esclavo durante más tiempo, lo conduzca a donde le parece. La formulación es, sin embargo, algo extraña.

debiese unir no solamente la posesión del difunto con la del heredero (*successio possessionis*), sino también la posesión del vendedor o donante, etc., con la sucesiva del comprador o donatario (*accessio possessionis*). Así, el *utrubi* clásico no era estrictamente *retinendae possessionis*, ya que podía servir también para recuperar una posesión recientemente perdida; sólo en el derecho justinianeo prevalece el nuevo principio de que venza siempre el poseedor actual.

Muy interesante es la reserva que se expresa en aquellas palabras del *uti possidetis*, "*nec vi nec clam nec precario alter ab altero*": violencia, clandestinidad y precariedad están aquí señaladas como circunstancias tales que obligan al poseedor actual a retirarse frente al no poseedor; éste se beneficia como el demandado de un proceso normal se beneficia con una excepción, de donde procede el nombre de *exceptio vitiosae possessionis*. Por violencia se entiende no sólo el haber entrado en posesión de la cosa despojando materialmente de ella al poseedor precedente, sino también el haber entrado en ella contra una expresa prohibición; por clandestinidad, el haber entrado en ella subrepticamente, de modo de ocultar el hecho a quien tenía interés contrario; por precariedad, el haber obtenido la posesión en virtud de una concesión revocable del poseedor precedente, y haber rehusado su restitución. Pero estos vicios no se entienden como objetivos, es decir, tales que hagan sucumbir al poseedor actual frente a cualquiera; las palabras *alter ab altero* están para significar que el vicio reduce la tutela de la posesión actual solamente si el procedimiento interdictal se desarrolla con relación a aquel que fué víctima de la violencia o clandestinidad, o del concedente en precario. Para indicar la posesión exenta de vicios, los juristas usan la denominación de *iusta possessio*; frente a la cual se llama *iniusta* la *possessio* viciosa.

En el formulario del *utrubi* parecería faltar una cláusula correspondiente; pero la jurisprudencia le extendió el régimen de los tres vicios⁵.

Los interdictos *recuperandae possessionis* son, por lo menos en el comienzo de la época clásica, dos: *de vi* y *de vi armata*. Pre-

⁵ Esta solución me parece sugerida por los textos, y especialmente por la confrontación entre D. 43, 31, 1 pr., y § 1, y GAYO, IV, 150 y 160. De otra manera LENEL, *Edictum*, 3ª ed., p. 489, y allí citados.

supuesto de ambos es que el poseedor de un inmueble⁶ haya sido expulsado de él con violencia; si concurren los extremos de la simple *vis*, el *deiciens* puede oponer la *exceptio vitiosae possessionis*, en virtud de la cual permanece en posesión si el *deiectus* poseía *vi* o *clam* o *precario* respecto de él; en cambio, si la violencia fué realizada a mano armada, no se concede la excepción, y el *deiciens* está obligado a la restitución en todo caso. Uno y otro interdicto sólo pueden hacerse valer dentro del año de la *deiectio*.

En derecho justiniano, se tiene un solo interdicto *de (o unde) vi*, al que no se le puede oponer nunca la *exceptio vitiosae possessionis*; el concepto en que se inspira esta reforma —de reprimir todo acto de defensa privada— encontró amplia aprobación en el mundo medieval, especialmente en el derecho canónico, y permaneció como fundamento de la acción de despojo o *redintegranda*, como lo dispone el art. 1168 del Código italiano. Aun conservando el principio de la ejercibilidad dentro del año, JUSTINIANO admite que en los límites del enriquecimiento del *deiciens* el interdicto *de vi* pueda intentarse aun después y también contra los herederos.

Es muy dudoso que pueda considerarse *recuperandae possessionis* el interdicto de precario, por el cual quien ha entregado la cosa en concesión precaria pretende su restitución del precarista infiel. La razón para dudar está sobre todo en esto: mientras los proculeyanos excluyen que varias personas puedan poseer la misma cosa, y consideran por esto que la posesión en precario priva de la posesión al concedente, los sabinianos entienden "eum qui precario dederit et ipsum possidere et eum qui precario acceperit" (D. 41, 2, 3 § 5). Según esta última opinión, nunca rechazada categóricamente por los juristas posteriores, el concedente que reclama la cosa al precarista, no tiende a recuperar una posesión perdida, sino sólo a reintegrar en su plenitud un goce que permanecía disminuido por la concurrencia del goce del concesionario.

El cuadro de los medios recuperatorios, concedidos contra la posesión viciosa de otro, tendría que ser completado por un *int. de clandestina possessione*; pero éste sólo se halla mencionado en D. 10, 3, 7 § 5, probablemente interpolado⁷.

⁶ Que para los muebles no exista un interdicto análogo, no puede maravillar; hemos, en efecto, visto cómo el *utrubi* tiene, en realidad, también la función de recuperación de la posesión ya perdida (aunque sea dentro de un término muy breve).

⁷ PEROZZI, *Ist.*, 2ª ed., I, 882.

La *possessio naturalis* (= retención), a la que nos hemos referido más arriba (p. 304), parecería contrapuesta, en las fuentes, antes que a la *possessio ad interdicta*, a una *possessio civilis*. Este nombre se da a la posesión en cuanto acarree consecuencias de derecho civil; *possessio civilis* es, en consecuencia, sinónimo de *possessio ad usucapionem* (o p. *bonae fidei*, o p. *ex iusta causa*): cfr. p. 237. Es muy discutido de qué modo esta distinción, que dejaría fuera a la posesión propiamente dicha, protegida por interdictos especiales, haya podido perdurar en la ciencia romana.

En el derecho justiniano se oscurecen los criterios distintivos fijados por los clásicos. A fin de hacer exhaustiva la antítesis entre *possessio civilis* y *naturalis*, es a menudo llamada *civilis* la *possessio iusta* y *naturalis* la *iniusta*, mientras para los clásicos una y otra entran en la categoría de la *possessio ad interdicta*. En general, pues, y no tanto en la compilación de JUSTINIANO como en los índices de las Basílicas y en las otras fuentes bizantinas, el contrapuesto de *φύσικη νομή* (= *possessio naturalis*) es una *ἐννομος νομή* (posesión legítima), que aunque no coincide con la *possessio ad usucapionem*, tampoco es la simple posesión *ad interdicta*, sino más bien un nuevo tipo de señorío, conforme a la equidad y no injustamente lesiva de la posesión de otro. Esto no representa solamente una confusión terminológica, sino la expresión de nuevas exigencias doctrinales y prácticas que tienden a restar valor, en cuanto sea posible, a la posesión no justificada por razones objetivas, y a vincular la tutela jurídica de la posesión con una presunción de buen derecho, encuéntrase o no en ella aquel presupuesto de la efectiva disposición de la cosa que era para los clásicos el eje de la doctrina posesoria. Tal tendencia permanece más bien señalada que claramente desarrollada en las citadas desviaciones terminológicas, pero sus signos más manifiestos están en el régimen de la adquisición y de la pérdida de la posesión⁸.

⁸ Sobre las cuestiones terminológicas, bastante debatidas, cfr. en especial RICCOBONO, *Zur Terminologie der Besitzverhältnisse* [Sobre la terminología de las relaciones de posesión], en la "Rev. Fundac. Savigny", 31, 1910, ps. 321 y ss., y el estudio posterior en los *Scritti in onore di G. P. Chironi*, I, ps. 377 y ss.; ALBERTARIO en los diversos escritos nuevamente editados (bajo el título *Distinzioni e qualificazioni in tema di possesso*) en *Studi di dir. rom.*, 2, ps. 183 y ss.; SUMAN, *Iusta et iniusta possessio*, en "Atti Ist. Veneto", 76, 1917, ps. 1607 y ss.; KUNKEL, *Civilis und naturalis*

§ 3. ADQUISICIÓN Y PÉRDIDA DE LA POSESIÓN

De la distinción que los juristas hacen entre los dos elementos de la posesión —disposición material de la cosa (*corpore possidere*) e intención de tenerla como dueño (*animus possidendi*)— resulta que para adquirir la posesión es necesario que concurren ambos. En cuanto al *corpore adquirere possessionem*, se ha hablado ya, para las aplicaciones en la adquisición a título derivado, a propósito de la *traditio* (p. 226); el desenvolvimiento que conduce de la entrega manual a las adaptaciones impuestas por exigencias prácticas (*traditio ficta*) concierne precisamente al pasaje de la disponibilidad material de la cosa, es decir, de la posesión. El requisito del *animus* excluye que la posesión sea adquirida por el loco, por el que duerme, por el infante, y hace necesaria la *auctoritas tutoris* para la adquisición del impúber; excluye también que la posesión pueda ser adquirida por quien recibe la cosa con la intención de tenerla *alieno nomine*. De la adquisición por medio de representantes se ha hablado en la p. 108.

Si para la adquisición se requiere el concurso de ambos elementos, resulta de ello que para la pérdida de la posesión basta con que falte uno solo. La intención de conservar la posesión nada cuenta frente al hecho de la *deiectio* o de la ausencia, que hace perder la disposición material; la conservación de la tenencia nada cuenta si a la intención de tener la cosa por sí, se ha sustituido la de tenerla para otro. Es necesario, sin embargo, de todos modos, un hecho nuevo o una nueva determinación de la voluntad: no se pierde la posesión durmiéndose, y ni siquiera enloqueciendo.

possessio, en *Symbolae Friburgenses in hon. O. Lenel*, 1933, ps. 40 y ss. El más vasto problema de la nueva concepción de la posesión en el derecho justiniano es afrontado, con ocasión de la investigación sobre la adquisición y la pérdida de la posesión, en el estudio póstumo de ROTONDI, *Possessio quae animo retinetur*, en "Bull. Ist. Dir. Rom.", 30, 1921, ps. 5 y ss. (= *Scr. giur.*, 3, ps. 94 y ss.), y con sospechas de más vastas interpolaciones en los estudios posteriores de ALBERTARIO (espec. *I problemi possessorii relativi al servus fugitivus*, Milano, 1929, hoy en *Studi cit.*, ps. 271 y ss.). Por último véase, en sentido más conservador, RABEL, *Studi Riccobono*, 4, ps. 205 y ss., y en un orden de ideas muy análogo al aquí acogido [JOERS-] KUNKEL, *Römisches Recht*, ps. 113 y s.

Sin embargo, ya algún jurista clásico (entre los proculeyanos especialmente) tiende a romper este rigor lógico, afirmando que en ciertos casos, no obstante la pérdida de la disposición material, *possessio animo retinetur*. Una de las primeras hipótesis a que tal máxima se aplicó es la de los *saltus hiberni et aestivi*, campos de pastoreo que por su destino no son aprovechados por el poseedor sino en determinada estación, y quedan de hecho abandonados en la parte restante del año. Una consideración objetiva de las relaciones, fundada sobre la valoración social de los bienes de que se trataba, habría podido llevar a considerar que en estos casos fuese conservada también la disposición de la cosa, con tal que el poseedor se sirviese del *saltus* toda vez que éste recuperase su utilidad; pero se prefirió considerar que se tratase de un caso excepcional en el cual, habiendo cesado momentáneamente la disposición material, bastase el *animus* para conservar la posesión.

Encontrada la fórmula, se hizo uso de ella también para otros casos, en los que la jurisprudencia anterior consideraba extinguida la posesión; tal el caso del *servus fugitivus*, del que se había considerado primero que la posesión se conservaba a los solos fines de la usucapión, pero que se perdía con relación a los interdictos; PAULO admite que también aquí la *possessio* subsista para todos los efectos, porque *animo retenta*, y que no sólo se posea al fugitivo mismo sino también todas las cosas que el amo poseía por su intermedio, y hasta que éste continúe adquiriendo la posesión de las cosas de las que aquél se vaya apoderando. En el derecho justiniano (al cual alguien atribuye la innovación últimamente recordada) se va aun más lejos, decidiendo que la posesión no se pierde si en ausencia del titular otro entra en ella, aun cuando la pérdida de la disponibilidad sea evidente (C. 8, 4, 11); que cuando la posesión se ejerce por medio de intermediarios, como el esclavo o el arrendatario, no cesa si éstos transfieren dolosamente la cosa a otro (C. 7, 32, 12); que hasta el prisionero de guerra, transformado por lo menos temporariamente en esclavo, conserve *animo* su posesión (D. 41, 2, 23 § 1 interp.).

La brecha que estas últimas disposiciones abren en el régimen romano de la posesión no carece de importancia; no solamente llevan a la prosecución indefinida de una posesión despojada de la disposición material de la cosa, sino que conducen a admitir una doble posesión del ausente y del ocupante, del locador y de quien

ha adquirido del locatario: tanto el primero como el segundo están defendidos con el *uti possidetis* contra todo tercero, y solamente cuando la litis se traba entre los dos prevalece la *possessio animo retenta*.

§ 4. LA CUASI POSESIÓN DE LAS COSAS Y LA POSESIÓN DE LOS DERECHOS

En la exposición que antecede hemos excluido de la posesión las cosas incorporeales: derechos de servidumbre, de usufructo, de crédito, de herencia. En efecto, definiendo la posesión como señorío sobre una cosa, no podíamos pensar más que en las cosas corporales.

Sin embargo, se puede considerar fácilmente al señorío sobre la cosa como un ejercicio del derecho de propiedad (corresponda o no este último al poseedor); y quien se coloca en esta corriente no puede dejar de reconocer una analogía entre la posición del poseedor y la de quien se comporta como titular de otro derecho; puede, en consecuencia, verse inclinado a llamar poseedor de una servidumbre de pasaje a quien se comporta como si fuese su titular, poseedor del crédito a quien es socialmente considerado como acreedor, etc.

Tal extensión analógica es frecuente en el derecho justinianeo, y frecuentísima en el derecho intermedio y en la ciencia moderna. Mucho más discutidos son los engranajes ofrecidos por el derecho romano antiguo y clásico.

Cierto es que en la edad antiquísima, la institución del *usus*, como goce de hecho que prolongado por cierto tiempo conduce a la adquisición (*usucapio*, cfr. ps. 230 y ss.), no era entendida como aplicable solamente a las cosas corporales, sino como válida para todos los derechos absolutos susceptibles de *actio in rem* (p. 130); en consecuencia, se usucapían, según el conocido versículo de las XII Tablas, no sólo las cosas susceptibles de *dominium ex iure Quiritium* sino también las servidumbres, la herencia, la tutela, la *manus maritalis*. Pero precisamente esta institución se llamaba *usus* y no *possessio*; tal nombre estaba reservado, en cambio, al señorío, perpetuo en el hecho, pero rigurosamente distinto

del *dominium ex iure Quiritium*, que los patricios se reservaban sobre las diversas fracciones del *ager publicus occupatorius* (ps. 204 y ss.). El hecho de que una vez acogida la idea de la posesión como reguladora del proceso de reivindicación, el *usus* haya sido atraído por el nuevo concepto, tomando el nombre de *possessio civilis* o *ad usucapionem*, no permite sacar inducciones del primitivo régimen del *usus* a la estructura de la posesión, pues la tendencia más reciente de nuestros estudios está justamente en el sentido opuesto.

Tanto más cuanto que la misma transformación del *usus* en *possessio civilis* tiene lugar en un tiempo en el cual el primero había perdido la originaria amplitud de aplicación; abolida por la *lex Scribonia* la usucapación de las servidumbres (p. 271), limitada a las cosas particulares del patrimonio hereditario la *usucapio pro herede* (p. 628), caído en desuso el *usus* con relación a la tutela y a la *manus* (p. 489), el concepto de la posesión *ad usucapionem* no era aplicado ya sino a las cosas. Y lo mismo sucedía con relación a la posición de las partes en el procedimiento: tampoco frente al heredero que intentaba la *hereditatis petitio*, la posición de demandado estaba determinada por la posesión de una supuesta cualidad o título de heredero, sino por poseer a título de presunto heredero esta o aquella cosa corporal perteneciente a la sucesión. El mismo orden de ideas prevalece, para quien bien observe, respecto de la actuación práctica de las facultades inherentes a los derechos sobre cosas de otro.

En realidad, hay casos en los cuales el titular o presunto titular de un derecho que garantiza el goce de una cosa, aun no siendo reconocido como su poseedor, es protegido por el pretor con interdictos análogos a los posesorios. Por ejemplo, entre varios aspirantes al goce de una *superficies* se da el interdicto *de superficiebus* (D. 43, 18, 1 pr.), análogo, en la formulación y en la regulación jurídica, al *uti possidetis* (salvo que en lugar del verbo *possidere* se encuentra en él la frase descriptiva "superficie ex lege locationis frui"); y así también entre varios aspirantes al goce de un usufructo (o también entre el aspirante al usufructo y el aspirante a la ilimitada posesión de la cosa) se dió, por la jurisprudencia clásica, un interdicto especial, en el que el *uti frui* sustituía al *possidere*. En estos casos, es siempre también la cosa el objeto del *uti frui* (o de la *ex lege locationis frui*); y el goce que de ella preten-

den las partes es tan afín a la posesión, que bien podía este o aquel jurista, sin chocar contra el rigor de los principios, usar a propósito, para la más fácil inteligencia del lector, la terminología posesoria. Parece que en este sentido estuviera, especialmente entendido el pasaje en que GAYO (IV, 139) recoge los varios tipos de controversias aquí señalados, en la frase "*cum de possessione aut quasi possessione inter aliquos contenditur*"⁹.

Como en tantos otros casos, tampoco aquí nuestro viejo maestro podía prever la importancia que a su inocente frase (como a las análogas aquí y allí proferidas por otros juristas) le darían los compiladores justinianeos, quienes trasformaron la *quasi possessio* en una categoría jurídica fundamental, no sólo aplicada a cada momento, sino trasportada a un significado muy distinto. En efecto, para JUSTINIANO la *quasi possessio* no es ya cuasi señorío sobre la cosa corporal (a título de superficie o usufructo), sino señorío sobre cosa incorporeal, es decir, sobre el derecho de superficie o de usufructo¹⁰.

Así establecido el criterio de la *quasi possessio*, ella se aplica amplísimamente a hipótesis en las que los clásicos no habían jamás pensado. Aquella particular posesión de cosas que hemos visto se requería en el demandado por la *hereditatis petitio*, se transforma en cuasi posesión de la *hereditas* como tal; y fácilmente se deja configurar también una *possessio iuris* con respecto a las servidumbres.

Para tutela del ejercicio de éstas, el pretor había concedido interdictos (*de itinere actuque privato*, *de aqua cottidiana et aestiva*, *de fonte*, etc.); pero a ningún jurista se le habría jamás ocurrido hablar a este propósito de *possessio* o de *quasi possessio*, ya que el goce de una servidumbre estaba muy lejos de aparecer como un señorío sobre la cosa. Pero cuando se consideran como

⁹ Que las palabras "aut quasi possessione" sean un glosema, como lo considera ALBERTARIO (ahora en *Studi* cit., ps. 324 y ss., 359 y ss.) y otros con él, no lo creo; el volverse a encontrar la frase también en las Instituciones justinianeas (4, 15 pr.) excluye a mi modo de ver la manipulación. Cfr. contra ALBERTARIO las finas observaciones de SEGRÈ, "Bull. Ist. Dir. Rom.", 32, ps. 293 y ss. (= *Scr. giur.*, 2, ps. 653 y ss.).

¹⁰ Sobre esto y sobre cuanto sigue cfr. especialmente ALBERTARIO, "Il Filangieri", 37, 1912, ps. 210 y ss., y en otro lugar (*Studi* cit., ps. 337 y ss., 409 y ss., etc.); primeras referencias en PEROZZI, "Riv. Ital. per la Sc. Giur.", 23, 1897, ps. 29 y ss., y DI MARZO, La "*possessio iuris*" nella "*hereditatis petitio*", en *Studi Moriani* (1905), 2, ps. 23 y ss.

objetos de posesión los derechos, es claro que la posición de quien ejerce una servidumbre se hace igual a la de quien ejerce un usufructo. Antes bien: el haberse limitado a las aplicaciones indicadas es, para el derecho justinianeo, sólo una supervivencia de la concepción expresada en el Edicto perpetuo.

Y por lo tanto no puede causar sorpresa que la ciencia moderna, retomando el pensamiento bizantino en su tendencia más original, quiera considerar como posesión de derecho cualquier situación de hecho correspondiente a una situación jurídica. Del campo de los derechos reales se pasa fácilmente a los que tienen una estructura análoga a la de éstos, hasta abrazar todos los llamados derechos absolutos; de estas a aquellas situaciones jurídicas complejas que toman el nombre de estado (*status*), el paso es breve (la denominación de "posesión de estado" es hoy admitida también en los códigos); y así también las situaciones correspondientes a los derechos de crédito son fácilmente atraídas hacia una órbita que tiende a abrazar toda especie de relaciones patrimoniales. Prosiguiendo todavía más, se llega a representar todo el ordenamiento jurídico no ya solamente como un sistema de derechos subjetivos y deberes jurídicos, sino como la superposición de dos sistemas, uno sucedáneo del otro: el sistema de los derechos y el sistema de las posesiones. Y he aquí que en este extenderse de su denominación para abrazar toda especie de relaciones de hecho que tenga relieve y efectos en el mundo jurídico, la posesión propiamente dicha, la de la jurisprudencia romana, se anega, en el sentido de que desaparece toda oportunidad científica de contraponerla como posesión de cosas a la posesión de los derechos, y más bien se la construye también a ella como posesión de un derecho, precisamente del derecho de propiedad¹¹.

Es innegable que en la base de esta doctrina hay una amplia visión de las relaciones jurídicas y sociales, y que las investigaciones más recientes hayan puesto en claro fenómenos descuidados sin razón por la doctrina precedente. Pero es lícito pensar que para tan vastos fines la institución de la posesión no pueda ser fundamento suficiente; en efecto, la extensión que a la doctrina de la posesión se le viene dando, tiene siempre lugar a expensas de aque-

¹¹ Aludo en especial a los profundos estudios de KRÜCKMANN, en *e*, "Archiv für die civilistische Praxis" ["Archivo para la práctica civil"], 108, 1911, ps. 179 y ss., y de FINZI, *Il possesso dei diritti*, Roma, 1918.

lla precisión de líneas que los romanos le imprimieron. Tal como la hemos descrito, ella puede valer solamente para el señorío sobre las cosas; con modificaciones tales que no alteren su estructura, puede extenderse a aquellas hipótesis de cuasi señorío que ya GAYO ponía a su lado, quizá también para representar la sombra de todo derecho real; cualquier extensión ulterior sólo es posible a condición de renunciar a establecer también una sola regla que sea aplicable a todo tipo de posesión.

FRANJA
MORADA

LAS OBLIGACIONES

CAPÍTULO XII

CONCEPTO Y DESARROLLO HISTÓRICO DE LA "OBLIGATIO"

En las Instituciones gayanas falta una definición de la *obligatio*; el comentario respectivo se inicia (III, 88) con un simple "nunc transeamus ad obligationes". Una definición, debida quizá a un glosador posclásico de GAYO, la encontramos en el lugar correspondiente de las Instituciones justinianeas (3, 13 pr.): "*obligatio est iuris vinculum, que necessitate adstringimur alicuius solvendae rei, secundum nostrae civitatis iura*". La definición es defectuosa precisamente en aquella parte que debería ser su núcleo: las palabras *alicuius solvendae rei*. Es sabido que del

¹ La literatura es infinita. Entre las obras de nuestro siglo, que han llevado el problema al campo histórico, está en primera línea la de PEROZZI, *Le obbligazioni romane*, Bologna, 1903; al lado de ella corresponde recordar los escritos de PACCHIONI (y especialmente los apéndices a su traducción de las *Obligaciones de SAVIGNY*); MARCHI, *Storia e concetto dell'obbl. romana*, I, Roma, 1912; ARANGIO-RUIZ, *Le genti e la città*, Messina, 1914, ps. 35 y ss.; BETTI, *La struttura dell'obbl. rom. e il problema della sua genesi*, Camerino, 1919; ALBERTARIO en muchos escritos (recopilados ahora en *Studi di dir. rom.*, III, Milano, 1936); SEGRÈ, *Studi Bonfante*, 3, ps. 499 y ss.; G. L. LUZZATTO, *Per un'ipotesi sulle origini e la natura dell'obbl. rom.*, Milano, 1934. Deben recordarse además varias investigaciones sobre temas especiales, que de éstos se elevan a una visión de conjunto, por ejemplo el de MITTEIS, *Ueber die Herkunft der Stipulation* [Sobre el origen de la estipulación], Berlín, 1907, y los análisis comparatísticos de PARTSCH y de KOSCHAKER. Hay que recordar también la obra de HAEGERSTROEM, *Der römische Obligationsbegriff*, Upsala, 1927-1941, especialmente por el potente análisis del formalismo romano al cual está dedicada el volumen II.

significado primitivo de desligar, el verbo *solvere* ha pasado a indicar el acto con el cual el deudor se desliga, es decir, el cumplimiento, lo que nosotros llamamos pago. Pero cuando a *solvere* o a *pagar* se agrega un complemento objeto, éste es siempre, tanto en latín como en castellano, una cosa o suma de cosas que el deudor da; de manera que si en nuestra definición tomamos a la letra el deber de "pagar alguna cosa", dejamos de lado las innumerables obligaciones que tienen un objeto distinto de la dación de una cosa. En cambio, si forzando la palabra se traduce *aliquid solvere* como *hacer un pago*, la definición no se precisa sino que se reduce a una mera tautología; decir que la obligación nos constriñe a hacer un pago es como decir que la obligación debe ser cumplida; pero ésta no es, en verdad, una definición. Quien quiere traducir bien, debe ajustarse a aquel inexacto "pagar alguna cosa" que el texto nos ofrece; quien quiere completar la definición según su mismo espíritu, debe entenderla como si dijese que la obligación es "un vínculo jurídico en virtud del cual estamos constreñidos frente a otro a determinada conducta".

Pero integrando y corrigiendo así la definición habremos definido un concepto mucho más general: el del deber jurídico. La definición a que hemos llegado se adapta tanto a la obligación del comprador de pagar el precio, como al deber de fidelidad conyugal; tanto a la obligación del mutuario de restituir la suma tomada en préstamo, como al deber de respetar la cosa y la mujer de otro. Esto es tan evidente que de un siglo a esta parte el esfuerzo más intenso de la ciencia jurídica ha estado dirigido a buscar el criterio diferencial de la obligación de los otros deberes. Esfuerzo tan persistente como vano, porque el criterio es inalcanzable. Con particular frecuencia se ha insistido en ver el criterio diferencial en el contenido económico de la conducta a observar; pero nada hay más falso y menos apto para distinguir la obligación de los otros deberes jurídicos. Falso, porque es perfectamente válida, por ejemplo, la obligación de no tocar el piano en cierto tiempo y lugar, o de cantar una serenata bajo una ventana; inepta para la distinción, porque tan económico es el contenido de las obligaciones del mutuario y del comprador como el del deber que cada uno tiene de no inmiscuirse en la cosa de otro. Cuando se dice que por falta de contenido económico no nace obligación de la promesa de bailar un vals, se olvida que en este caso falta no sólo la obligación,

sino la *juridicidad* del deber; tanto es así que no se contrae obligación jurídica ni siquiera invitando a alguien a almorzar, lo que puede tener a veces notable valor económico para el invitado.

En realidad, las clasificaciones fundamentales de las relaciones jurídicas derivan no de una diversa configuración de los deberes particulares (los cuales, como unidades elementales del mundo jurídico, no presentan diferencias fundamentales de estructura), sino de la valoración económico-social del conjunto de las situaciones jurídicas en las cuales se injertan los diversos deberes. Hemos visto un ejemplo característico a propósito del concepto de derecho real (ps. 193 y ss.); lo mismo se podría decir de los deberes inherentes al derecho de familia, de sucesión, etc. Por lo que se refiere a la obligación, los deberes jurídicos que toman este nombre llevan en sí, más o menos marcados según los tiempos y los lugares, el estigma de la sujeción del hombre al hombre, del límite a la libertad individual, y, en consecuencia, de la excepcionalidad; por eso la *obligatio* tiene tanto más relieve en la conciencia jurídica cuanto más se retrocede hacia las condiciones primitivas de existencia, en las cuales el crédito representa una desviación de la sana economía familiar, y tanto más se oscurece y confunde en el gran mar de los deberes, cuanto más el crédito se transforma en la norma de las relaciones económicas². En la definición que hemos leído es quizá una ilusión nuestra dar tanta importancia a las palabras "*alicuius solvendae rei*"; y es, por cierto, fruto de una conciencia jurídica trasformada, considerar como simples e inocentes metáforas al "*vinculum iuris*" y al "*necessitate adstringi*"; en la concepción de los antiguos, el vínculo, que también tiende a trasformarse en ideal, se inspira en el recuerdo del deudor sometido a la *manus iniectio* y retenido con cadenas por

² Si hoy se tiende a hacer prevalecer en el concepto de obligación la consideración del bien económico a cuya realización tiende la obligación misma; si se propone insistentemente renunciar a considerarla como una relación entre hombres, para construirla, en cambio, como relación entre patrimonios; si hay quien querría considerar a la obligación de *dare* como un deber jurídico de *dejar tomar*; si algún consecuenciario que no teme la paradoja llega a la negación del deber jurídico del deudor y a la concepción del derecho de crédito como facultad de extraer del patrimonio ajeno cierta ventaja; esto deriva precisamente de ser la deuda, en la conciencia moderna, no más sumisión sino relación paritética, no más un hecho patológico de determinadas economías individuales, sino un evento normal y frecuente en la vida de cada uno.

el acreedor; y la *necessitas* que lo constriñe es una carga que pesa sobre él, distinguiéndolo penosamente entre la multitud de co-asociados.

La prueba de lo que decimos está en la historia de la primitiva *obligatio*. Por mucho que una corriente difundida entre los romanistas modernos exagere en querer a toda costa aplicar al derecho de Roma, y no sólo al derecho antiguo sino al de la jurisprudencia clásica, esquemas conceptuales extraídos del derecho de otros pueblos (y del derecho germánico especialmente), lo cierto es que antiguamente la *obligatio* no consiste en el puro y simple deber, libremente asumido, de observar frente a alguno tal o cual otro comportamiento, sino en la sumisión al poder doméstico del acreedor propio o de otro, sumisión que es en la conciencia social del tiempo tan notable como para relegar a segundo plano el deber de conducta a que se vincula. Si bien es cierto que la más antigua relación de deuda y de crédito nace del mutuo, es decir, de una dación de dinero o de otras cosas fungibles con la obligación por parte del que las recibe de restituir otro tanto dentro de cierto término, también lo es que esta relación no fué en los orígenes reconocida como *obligatio*; tal nombre fué, en cambio, atribuido al *nexum*, es decir, a la *mancipatio* de sí mismo que el deudor hacía para ofrecer una garantía al acreedor, probablemente con el efecto de someterse a su poder hasta tanto hubiese igualado con el propio trabajo la suma debida, y rescatado así la propia libertad. En otros campos, especialmente en la *praedictura* y en la *sponsio*, se tiene una separación neta entre el deber de observar el comportamiento contractualmente fijado, que pesa sobre una persona, y la relativa responsabilidad que recae sobre otra; así, en el procedimiento de la *legis actio sacramenti* (p. 130), el deber eventual de pagar la *summa sacramenti*, prometida para el caso de sucumbir, es de los litigantes, pero el procedimiento relativo de ejecución, por parte del erario al que está destinado el monto de la apuesta, se dirige no contra el vencido sino contra sus garantes (*praedes sacramenti*: GAYO, IV, 16); en las adjudicaciones de los impuestos públicos, es el adjudicatario (*manceps*) quien debe entregar al erario la suma prevista, pero también aquí la ejecución se dirige, en caso de incumplimiento, no contra él sino contra los *praedes*; en la antiquísima *sponsio*, la promesa solemne no se cambia entre el acreedor y quien asume frente a él el deber de una presta-

ción cualquiera, sino entre el acreedor y un garante. En suma, el *obligatus* no es un deudor en el sentido moderno, sino una persona sobre la cual el acreedor puede tomar satisfacción en caso de incumplimiento, sin importar que la inejecución sea suya o de otro; es, en otros términos, una prenda o un rehén, y se dice *obligatus* en el mismo sentido y, por lo menos aproximadamente, con los mismos efectos por los que se da el nombre de *res obligata* a la cosa dada en garantía (cfr. p. 291). Pero todo esto subsiste sólo en la época primitiva; posteriormente, la evolución de la *sponsio* (que es, entre todos los negocios mencionados, el más vital) se produce en el sentido de que la promesa se cambia entre acreedor y deudor, salvo la eventualidad de una promesa accesorio del garante; y por eso en la ciencia jurídica romana (que nace una vez cumplido el desarrollo) *debitum* y *obligatio* son la misma cosa. Los contratos ulteriores (máxime los del *ius gentium*, como la compraventa) surgen en este nuevo ambiente. Residuo de la antigua concepción es la íntima conexión que los juristas clásicos ven entre *obligatio* y *actio*: ésta, que es el medio ofrecido al particular para la actuación de cualquier derecho subjetivo, se presenta con preferencia al pensamiento jurídico como la posición avanzada de la obligación (también el Digesto tiene un título [44, 7] de *obligationibus et actionibus*). Mientras ocurre con relativa frecuencia que los derechos reales, y más todavía los de familia y sucesión, sean descritos en el estado de reposo y de goce pacífico, la obligación es considerada con preferencia en la lucha para obtener su cumplimiento.

En este segundo estadio de la evolución, que está ya cumplido al fin de la época republicana, la idea de *obligatio* se extiende de los deberes contractuales a los de delito. El desarrollo de éstos se había producido hasta este punto por una vía completamente autónoma; el delito privado, es decir, aquel cuya sanción depende de la iniciativa del ofendido (cfr. p. 121 y cap. XVI), era pasible originariamente de una venganza sobre la persona, y sólo posteriormente la venganza se evitó con el pago de una suma de dinero a título de composición; la composición fué, a su vez, en una primera época, convencional, es decir, abandonada al libre acuerdo entre ofensor y ofendido, pero en un segundo período fué legal, es decir, impuesta por el Estado, sea que estuviese determinado *a priori* también el monto, sea que la determinación correspondiese